

Así, ha dicho que "la interpretación del documento que nos rige no debe, pues, efectuarse de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida; cada una de sus partes ha de entenderse a la luz de las disposiciones de todas las demás" (9).

c) Interpretación historicista

Aquí se procura indagar la voluntad del constituyente, tal como el mismo la plasmó al momento de redactar el plexo de base. En Estados Unidos, se conecta con lo que dio en denominarse "jurisprudencia de la intención originaria de los Padres Fundadores de la Constitución", y revela por cierto un tamiz bastante conservador, ya que "congela" la intención del autor al tiempo de la redacción del precepto.

d) Interpretación dinámica

Si se quiere es la cara contraria de la anterior (10). Predica que el texto constitucional es pasible de lecturas *evolutivas*. Su análisis se basa en el contexto fáctico del momento del hecho interpretativo, sin retrotraerse a la voluntad histórica del autor de la norma. Valora, en síntesis, las circunstancias y las condiciones políticas, económicas y sociales al tiempo de producirse la interpretación (11). Así, la Corte ha expresado: "Su interpretación auténtica no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad que le impide envejecer con el cambio de ideas, crecimiento o redistribución de intereses, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la Nación" (12).

e) Interpretación teleológica o finalista

Como su nombre lo indica, indaga los *fin*es que pudo tener en vista el autor de la norma constitucional. Cada norma porta o contiene fines o valores que es menester auscultar. Señala al respecto Gregorio Badeni (13): "al margen de los juicios subjetivos que le pueda merecer la norma constitucional, su intérprete debe conocer y respetar lealmente los fines que la motivan, recordando que la constitución está asentada sobre una idea política motriz que caracteriza a la organización política y a la estructuración social".

(9) Fallos: 312:496.

(10) Bien han expresado Eskridge y Frickey que "for every canon there is a counter-canon". V. LÓPEZ BOFILL, HÉCTOR, *Decisiones interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley*, Valencia, 2004, p. 262. Es que en materia de interpretación del derecho constitucional, no hay purezas metodológicas. V. HARO, RICARDO, *El control de constitucionalidad*, Buenos Aires, 2003, p. 198.

(11) V. CARNOTA, WALTER F., (Director), *Curso de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2001, p. 20.

(12) Fallos: 178:22.

(13) V. BADENI, GREGORIO, *Tratado de Derecho Constitucional*, tomo I, Buenos Aires, 2004, p. 91.

En efecto, útil siempre es recordar la axiología de base del constitucionalismo, que es limitar al ejercicio abusivo del poder.

f) Interpretación previsora

Dentro del marco interpretativo, el operador tiene en cuenta los efectos y las consecuencias de su labor, eventualmente readaptando su producto hasta hallar la solución adecuada.

Dice Sagüés que "al juez constitucional no puede serle indiferente qué es lo que resuelve, so pretexto de que cumple su tarea si se limita a aplicar automática y asépticamente a la regla constitucional, como si fuese un teorema algebraico o un silogismo puramente lógico. Su papel de Poder del Estado y de operador de una Constitución-instrumento de gobierno le obliga a meritarse y ponderar cuidadosamente las secuelas de sus pronunciamientos" (14).

Hoy en día el consecuencialismo se ha emparentado en una de sus vertientes con el análisis económico del derecho, y con el consiguiente estudio del efecto económico de las decisiones judiciales.

6. LA INTERPRETACIÓN COMPARADA, ¿ES DE UTILIDAD?

Se ha venido planteando en los últimos tiempos, fruto del acusado proceso de globalización en el que vivimos, si no asume capital importancia la interpretación comparada. Concretamente, Häberle ha sugerido adicionarla como "quinto método" al tradicional listado que en su momento elaboró Savigny (15).

No quedan dudas de que las sociedades suelen enfrentar desafíos constitucionales similares, y allí está el derecho constitucional comparado como herramienta de auxilio y de ayuda.

En los últimos tiempos, se ha discutido mucho si la jurisprudencia comparada, es decir, aquella que dimana de tribunales extranjeros o eventualmente internacionales, es relevante para el intérprete nacional o doméstico.

Así, en la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, las opiniones se encuentran divididas. Mientras que el juez Breyer admite recurrir a fuentes extranjeras para la solución de los diversos conflictos de interpretación, su par Antonin Scalia es extramadamente renuente a acudir al derecho extranjero (16),

(14) V. SAGÜÉS, NÉSTOR P., *La interpretación judicial de la Constitución*, Buenos Aires, 1998, p. 40. MARANIello, PATRICIO A., "Declaración de inconstitucionalidad con efecto diferido (caso 'Rosza')", LA LEY, del 22/7/2007.

(15) V. VALADES DIEGO (Compilador), *Conversaciones académicas con Peter Häberle*, México, 2006, p. 11, entre muchas otras.

(16) V. "A conversation between U.S. Supreme Court justices. The relevance of foreign legal materials in U.S. constitutional cases. Justice Antonin Scalia and Justice Stephen Breyer", en "International Journal of Constitutional Law", New York, octubre de 2005, vol. 3, núm. 4, p. 519.

con excepción de los supuestos en que se hallen en juego tratados internacionales. Incluso algunos proyectos de ley hace un par de años atrás propiciaban en los Estados Unidos vedar a los jueces federales la cita de derecho extranjero, con la salvedad del derecho común inglés (17).

Bien se ha aclarado que una cosa es la relevancia que el material extranjero pueda llegar a tener en el área de los derechos fundamentales (libertad de intimidad, libertad de prensa, pena de muerte, derecho a la vida) que en general son parecidos en todo el mundo, mientras que la ejemplaridad es más escasa en temas estructurales del poder, como la forma de estado o la de gobierno, que son propios de cada Estado (18).

7. RUMBOS DE LA TRATADÍSTICA CONSTITUCIONAL

En su tarea interpretativa, la doctrina de los autores se ha orientado hacia dos grandes modelos. Por un lado, se ha seguido la línea que comenzó Joseph Story en los Estados Unidos en el año 1833, siguiendo un orden exegético y sistemático en el análisis constitucional. Así, en nuestro medio, las clásicas obras de Joaquín V. González y de Juan Antonio González Calderón han seguido esa impronta, entre otras.

Por el otro, los aportes de Noel Dowling, Herbert Wechsler y sobre todo Gerald Gunther han girado en torno al estudio de los principales precedentes judiciales, siguiendo las aguas del famoso "método de casos".

Hoy en día no se conciben a ambos enfoques como opuestos o irreconciliables, y bien pueden tratarse las principales instituciones del derecho constitucional, sin desdeñar ni mucho menos las sentencias judiciales más pertinentes.

(17) V. CARNOTA, WALTER F., "Interpretación internacionalista de nuestra Corte Suprema", LA LEY, 17 de abril de 2006, ps. 1 y sigtes.

(18) V. JACKSON, VICKI, "Comparative constitutional federalism and transnational judicial discourse", en *International Journal of Constitutional Law*, New York, enero de 2004, vol. 2, núm. 1, p. 100 y sigtes.

CAPITULO III

SUPREMACÍA Y CONTROL CONSTITUCIONAL (1)

SUMARIO: I. Supremacía constitucional. — 1. Génesis del concepto. — 2. La supremacía en el derecho constitucional comparado. — 3. Significado e implicaciones del concepto de supremacía constitucional: su vinculación con la teoría de la fuerza normativa de la Constitución. — 4. La supremacía en la Constitución Nacional. a) Relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional. b) Relación entre la ley interna y el tratado internacional. b.1. El caso "Ekmekdjian c. Sofovich": Trabajo práctico. — II. Control de Constitucionalidad. 1. Orígenes del control de constitucionalidad. — 2. "Marbury v. Madison": La Corte empieza a ser Suprema. — 3. La supremacía en la Constitución Nacional. — 4. Los grandes sistemas del control de constitucionalidad en el derecho comparado. La jurisdicción constitucional específica. — 5. El control de constitucionalidad a nivel federal en Argentina. — 6. Problemas de teoría constitucional que arroja el control judicial: ¿hay una "dificultad contramayoritaria"? — 7. ¿Nulidad o declaración de inconstitucionalidad de la reforma constitucional? Jurisprudencia: El caso "Fayt".

I. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

1. GÉNESIS DEL CONCEPTO

Todo el andamiaje del constitucionalismo moderno descansa sobre la premisa de que en el ordenamiento jurídico prevalece un documento o instrumento escrito, que tiene jerarquía cimera y cuya reforma es factible solamente por medio de procedimientos especialmente dificultosos.

El primer carácter (escrito) es el propio de las constituciones formales, codificadas, del tipo "racional-normativo". La segunda característica se vincula con la supremacía constitucional. La tercer nota distintiva tiene que ver con la noción de *rigidez*.

Para una constitución, entonces, la supremacía es una cualidad definitiva o esencial, puesto que la primera es "derecho fundamental de organización del Estado". Quizás una de las pocas excepciones sea Gran Bretaña que tiene una clase dispersa y evolutiva de constitución, más material que formal.

(1) V. CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Bs. As., 2005, ps. 33 y sigtes.

La inmensa mayoría de las constituciones contemporáneas reivindica este señalamiento de *suprema*. En este contexto, debe entenderse por tal la condición de predominio formal sobre el resto del orden jurídico. La constitución es fuente de validez de todas las demás normas positivas; es "norma de normas"; es "ley de leyes".

Ahora bien, ¿cuándo comienza exactamente a destacarse esta impronta de supremacía constitucional? Paradojalmente, en Inglaterra durante el s. XVII. En el interregno republicano de Oliverio Cromwell, se plasmó la organización del poder en un documento, denominado "Instrument of Government" del 16 de diciembre de 1653, dos de cuyas cláusulas establecían la nulidad de las leyes contrarias al mismo (2).

Demás está decir que esta pauta no se ejemplarizó con ulterioridad en el derecho inglés que, para 1689, acentuó el principio de supremacía del Parlamento (y no de la constitución). Empero, este lineamiento se filtró a las colonias inglesas de América del Norte (3).

El bagaje doctrinario de la supremacía logra consagración positiva con la constitución de Filadelfia de 1787. En efecto, el art. 6º, cláusula segunda, estatuye: "*Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se promulgarán, y todos los tratados hechos, o que se hicieren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema del país, y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición contraria en la Constitución o en las leyes de los Estados*".

De ahí, este principio se trasvasó al derecho público de casi todo el mundo, como puede constatarse al leerse el art. 31 de la Constitución Nacional de 1853: "*Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia estarán obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales*".

2. LA SUPREMACÍA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Cabe destacar que en la evolución que el principio de supremacía registra a lo largo del s. XX, no hay una sola modalidad de supremacía. Para decirlo de otro modo, hay diversas maneras de visualizar la supremacía constitucional.

A mediados del s. XX, y con motivo de los trágicos hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, se advirtió que la supremacía constitu-

cional había sido impotente para impedir las atrocidades cometidas en su transcurso. Allí entonces se pensó que el orden constitucional no podía en solitario garantizar que no volvieran a repetirse las groseras violaciones cometidas contra los derechos humanos más elementales. En esta inteligencia, se empieza a destacar el emergente de la cooperación internacional. El lanzamiento de la Organización de las Naciones Unidas (1945) y la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) son hitos significativos de este proceso.

Podemos, en tren de simplificar (4), encontrar tres sistemas básicos de articulación del principio de supremacía constitucional con el derecho internacional público.

1. Un primer esquema está dado por la supremacía del derecho internacional por sobre todo el ordenamiento jurídico interno, incluida la propia Constitución, como hace la Constitución de los Países Bajos, aún en su versión actualizada (5).
2. Un segundo modelo asigna prelación al derecho internacional de los derechos humanos por sobre todo el derecho doméstico. En esta línea se enrola la Constitución colombiana de 1991 (6).
3. Finalmente, el tercer sistema indica paridad de rango entre el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución, como hace nuestro art. 75 inc. 22 reformado en 1994 (7).

3. SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DEL CONCEPTO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: SU VINCULACIÓN CON LA TEORÍA DE LA FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN

Debe dejarse en claro que el concepto de supremacía no es una cáscara vacía de contenido. Por el contrario, la afirmación de que la Constitución es suprema conlleva importantes consecuencias. Así, decir que se encuentra en la cúspide o cima del ordenamiento jurídico, implica —ni más ni menos— que todas las normas "infraconstitucionales" (es decir, las que están jerárquicamente colocadas por debajo de ella) le deben fidelidad y acatamiento, o sea, deben ser congruentes con ella.

La Constitución se muestra de ese modo como fuente de validez de todo el orden normativo. Y es dadora de legalidad, con preceptos que obligan de manera imperativa ("orden público constitucional").

(4) Conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, t. I, Buenos Aires, p. 108. Se suministra ahora una visión simplificada del esquema que allí oportunamente desarrollamos.

(5) Conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., ob. y t. p. cit.

(6) Idem cita anterior.

(7) Conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., ob. y t. cit., ps. 108/109.

(2) V. AJA ESPIL, JORGE A., "Origen y desarrollo del control jurisdiccional en los Estados Unidos de Norteamérica", Separata de la Revista Jurídica de Buenos Aires, 1958-II, p. 5. Véase también LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*, t. I, Buenos Aires, 1976, p. 496.

(3) V. LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., ob. y t. cit., p. 497.

En Alemania y en España, se ha desarrollado lo que ha dado en llamarse "teoría de la fuerza normativa de la Constitución". Se parte de la base de que la Constitución es norma jurídica obligatoria ("derecho de la Constitución"), y que en esa inteligencia sus mandatos sujetan tanto a los poderes públicos constituidos cuanto a los particulares. Y ello tiene mucho que ver con el carácter supremo del texto constitucional, dado que desde su especial sitial ilumina al resto de las normas y actos.

Un claro ejemplo de elaboración práctica de la "fuerza normativa" de la constitución se observa en el art. 9º, párr. primero, de la Constitución española de 1978, que prescribe: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" (8).

4. LA SUPREMACÍA EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

En 1853, como ya adelantáramos, se consagró la clásica fórmula de supremacía, como eco del art. 6º cláusula segunda de la constitución de Filadelfia, en el art. 31 ya cit., con su agregado final de 1860: "salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto del 11 de noviembre de 1859".

Cabe destacar que este enunciado no suscitó mayores dudas interpretativas, salvo para recalcar que era dable discernir *dos* principios —y no uno solo— de supremacía constitucional.

En efecto, nuestro plexo de base se autoproclama o autodefine como "ley suprema", puesto que es él quien encabeza la nómina contenida en el art. 31. Pero, como se lee fácilmente, hay otros elementos (leyes, tratados) que también los caracteriza como "ley suprema". ¿En relación a qué son supremos? No nos olvidemos que nuestra forma de estado (arts. 1º, 5º, y conc.) es federal: respecto de la normativa de derecho provincial.

En el derecho argentino, también se presentaron —antes de 1994— conflictos de jerarquía entre el orden constitucional y el orden internacional.

a) Relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional

Dijimos que en general el principio de supremacía constitucional no fue seriamente controvertido.

Empero, en el tristemente célebre caso "Merck" (9), nuestra Corte —en decisión afortunadamente aislada— entendió que en épocas de guerra pre-

(8) Se ha tejido —en torno de este precepto— abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, como se muestra en los extractos consignados por RUBIO LLORENTE, FRANCISCO, *Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina Jurisprudencial)*, Madrid, 1995, p. 62.

(9) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 9 de junio de 1948, Fallos: 211:162.

valecía el derecho internacional por sobre la Constitución (denominando a esto "monismo") y que en tiempos de paz y normalidad predominaba la Constitución (y ello nombró "dualismo").

b) Relación entre la ley interna y el tratado internacional

La Corte Suprema entendió a partir del caso "Martín c. Administración General de Puertos" (Fallos: 257:99), siguiendo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que la ley interna y el tratado internacional tenían idéntica gradación jerárquica. En consecuencia, al darse esa equivalencia, prevalecía para su aplicación la última norma en el tiempo, recurriendo al criterio de "*lex posterior*".

Ello despertó la crítica doctrinaria, en tanto el tratado es un acto complejo, dado que concita la voluntad concordante de dos o más estados o la concurrencia de un organismo internacional.

A partir del caso "Ekmekdjian c. Sofovich" (sentencia del 7/7/1992, Fallos: 315:1492), nuestro más Alto Tribunal —sobre la base de la adhesión del Estado argentino a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados— interpretó que debía darse prioridad al tratado internacional, receptando de ese modo las prevenciones que vimos precedentemente, y las ideas más actualizadas sobre el tópico.

b.1) El caso "Ekmekdjian c. Sofovich": Trabajo práctico

1. La doctrina constitucionalista diferencia entre el "holding" de una sentencia (es decir, su parte medular, que sienta jurisprudencia) del "obiter dictum" (argumentos que da el juzgador a mayor abundamiento) (ver, para el distingo, Van Geel, T.R., "Understanding Supreme Court Opinions", New York, 1991, ps. 98 y sigtes.).

En el caso ocurrente, el accionante pretendió que se concediera "derecho de réplica" en los términos del art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica, frente a los dichos del escritor Dalmiro Sáez que agraviaban a la Virgen María. La Corte hizo lugar al pedido.

¿Habla el art. 14 de "réplica"? ¿Cuáles son las hipótesis que concretamente contempla? ¿Se agravió aquí al actor a título personal?

Por lo demás, ¿cuál es la argumentación que despliega la Corte como "holding"? ¿Y cuál como "obiter"? ¿Cómo se compagina su tesis con la asumida en el primer caso "Ekmekdjian" (Fallos: 311:2497).

2. ¿Cree Ud. que la norma consagratória del "derecho de rectificación o respuesta" es operativa (o sea, directamente aplicativa o autoejecutoria, sin necesidad de desarrollo legislativo ulterior), o que por el contrario es programática (plan de acción futuro, sujeto a posterior reglamentación legal). Fíjese, en tal sentido, cómo está redactada la citada previsión del art. 14.

3. Además, la Corte abandona el criterio adoptado en "Martín" y rescata el predominio del tratado internacional en el orden jurídico interno. ¿Ella es "holding" u "obiter dictum"? No debe olvidarse que esta tesis fue base de la reforma que sobre el punto luego introdujo la revisión constitucional federal de 1994.

4. Según esta sentencia, los tratados prevalecen sobre el derecho interno. ¿Son también superiores a la propia Constitución? Analice el problema a la luz de este pronunciamiento, de los arts. 17 y 31 C.N., y de la posición a la que arribó la Corte exactamente un año después en "Fibraca" (sentencia del 7/7/1993, Fallos: 316:1669).

5. ¿Tiene la decisión implicancias para el proceso de integración desata-
do por el MERCOSUR? Sustente su postura en algún tramo del fallo.

b.2) El impacto de la reforma constitucional de 1994

Indudablemente, la incidencia de la revisión constitucional de 1994 fue en este tema —como en tantos otros— vasta.

Cabe apuntar que el art. 7° de la ley 24.309 de necesidad de reforma impe-
día tocar los primeros treinta y cinco artículos ("parte dogmática").

Ni el art. 27, ni el 31, estaban en discusión. Sin embargo, la ley habilitó un punto, por el que se permitía la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos. Ello sirvió para diseñar al art. 75 inc. 22 C.N., que de esa forma se transformó en la norma más importante de la Constitución. No todos los autores estuvieron de acuerdo con el procedimiento empleado. Como sea, a nuestro juicio la Asamblea pudo válidamente actuar como lo hizo, sobre la base de la ya mentada habilitación contenida en la ley de reforma.

Este artículo consagra pautas fundamentales en la temática en estudio:

1. Desde un ángulo jerárquico, va a consagrar la "jerarquía constitucional" de ocho tratados, dos declaraciones y un protocolo facultativo, pertenecientes al derecho internacional de los derechos humanos.

2. La peculiaridad de la enumeración se ve mitigada con su carácter enun-
ciativo y no taxativo, en la medida en que con mayorías especiales el Congreso puede adicionar —como hizo en 1997 con la "Convención sobre Desaparición Forzada de Personas" y en 2003 con la de "Imprescriptibilidad sobre Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad"— o sustraer la "jerarquía constitucional".

Dicha caracterización no significa que estos documentos integren pro-
piamente la Constitución formal; tienen su mismo rango en el vértice de la pirámide jurídica.

3. Estos documentos tienen el común denominador de regular derechos humanos, sin perjuicio que algunos son tratados, hay dos declaraciones, al-
gunos tienen alcance regional (la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, o Pacto de San José de Costa Rica), otros universal (los Pactos de

Naciones Unidas de 1966), con destinatario específico (Convención sobre los
Derechos del Niño, o sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación a la Mujer) o con temática puntual (Tortura).

4. Se vuelca la doctrina de "Ekmekdjian II" y de "Fibraca", asignando pre-
lación a los tratados —sean o no de derechos humanos— por sobre la ley del
Congreso, reforma por cierto que también vemos en el nuevo art. 43, primer
párrafo.

5. Se dan tres directivas para que los tratados puedan gozar de la apun-
ta-
da "jerarquía constitucional":

- no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución;
- los derechos que consagran deben entenderse como complementa-
rios de los estipulados constitucionalmente;
- la interpretación de los textos de los tratados debe hacerse "en las
condiciones de su vigencia", es decir, tal como el instrumento rige en
la órbita internacional (10).

Ahora sí estamos en condiciones de examinar concretamente la previsión
lexical del art. 75 inc. 22, al facultarse al Congreso de la Nación a:

*"Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa
Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño;
en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella recono-
cidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre
derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán*

(10) Acertados enfoques sobre esta norma pueden verse en BIDART CAMPOS, GERMAN J., *Los
Tratados Internacionales y la Constitución Nacional*, Buenos Aires, 1994; CAFIERO, JUAN PABLO y
GRAHAM, MARISA A., *Tratados sobre Derechos Humanos*, en VEGA, JUAN CARLOS y GRAHAM, MARISA
ADRIANA (Dir.), *Jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales*, Buenos Aires, 1996, p. 27.

del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

[Téngase en cuenta que por ley 24.820 (1997), se otorgó jerarquía constitucional a la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” y por ley 25.778 (2003) se confirió análogo rango a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de Lesa Humanidad].

6. Asimismo, debe computarse la norma del art. 75 inc. 24, que expresa:

“Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

II. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

1. ORÍGENES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Como vimos, desde fines del s. XVIII empezó a tomar adecuada forma la doctrina de la supremacía constitucional. Empero, no se encontraba resuelto el problema de quién, cómo y cuándo controla la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos.

Se han querido rastrear antecedentes del control constitucional en la antigua Grecia (Atenas) con la institución de la *graphé paranomon* y en el Justiciero Mayor aragonés de la Edad Media.

De manera menos remota, puede afirmarse que uno de los atisbos del control de constitucionalidad puede verse en el célebre caso judicial inglés del “Dr. Bonham” en el año 1610. En dicha ocasión, el magistrado Sir Edward Coke planteó la superioridad del “common law” respecto de las leyes del Parlamento. En la especie, sostuvo que la legislación que permitía la aplicación de sanciones por parte del Real Colegio de Médicos no podía alzarse

contra el principio del derecho común por el cual nadie puede ser juez y parte a la vez en una contienda (11).

La constitución de Filadelfia de 1787, si bien contempló la doctrina de la supremacía constitucional en el mencionado art. VI, cláusula segunda, no previó el mecanismo para tornarla efectiva como es el contralor o inspección de constitucionalidad (12).

Habría que esperar hasta el año 1803 en donde en el famoso caso “Marbury versus Madison” (13), la Corte Suprema norteamericana inaugura —en el mundo— el dispositivo del control judicial de constitucionalidad difuso bajo la forma de creación pretoriana o de derecho judicial.

2. “MARBURY V. MADISON”: LA CORTE EMPIEZA A SER SUPREMA

El precedente “Marbury” es sin dudas el caso judicial más relevante de todos los tiempos. Cientos de análisis se han escrito en torno suyo, hasta prácticamente alcanzar ribetes mitológicos (14).

Cabe destacar que en los primeros años de vida independiente, la Corte norteamericana era una dependencia gubernamental más. A partir de este caso, redactado por su tercer presidente John Marshall, la Corte va a ser realmente “suprema”.

Los hechos que dieron vida al caso son bastante conocidos (15). Recordemos que hacia febrero del año 1801, el presidente John Adams, de extracción

(11) Ver, en sentido análogo, AJA ESPIL, JORGE A., art. cit., ps. 5/6. Una reseña de antecedentes puede consultarse en CAPPELLETTI, MAURO, y ADAMS, JOHN CLARKE, “Judicial Review of Legislation: European Antecedents and Adaptations”, en “Harvard Law Review” núm. 79, p. 1207 y sigtes. (1966). Se ha dicho que “en el desarrollo del *common law* en Inglaterra, hubo, de vez en cuando, opiniones judiciales que sostenían que los tribunales tenían la facultad de declarar inconstitucionales leyes que fueran contrarias a los principios del *common law*”. V. BARKER, ROBERT S., *La Constitución de los Estados Unidos y su dinámica actual*, Lima, 2005, p. 45. Respecto de una visión crítica del famoso “Bonham’s case”, véase REY MARTÍNEZ, FERNANDO, “Una relectura del Dr. Bonham’s case y de la aportación de Sir Edward Coke a la creación de la *judicial review*”, www.eldial.com, 19/3/07, DCAEL.

(12) “Ni ahí ni después se dijo nada acerca de otorgar a la Corte Suprema el poder de aprobar la constitucionalidad de las leyes del Congreso”. Conf. VAN DOREN, CARL, *The Great Rehearsal (The story of the making and ratifying of the Constitution of the U.S.)*, New York, 1976, p. 135. “Los fundadores no previeron ningún papel especial para el Poder Judicial en su búsqueda de su ideal de unanimidad”. Conf. BURT, ROBERT A., *Constitución y Conflicto*, Buenos Aires, 2000, p. 77. Sin embargo, Hamilton en “El Federalista”, núm. 78 se muestra fervoroso partidario del control judicial de constitucionalidad. Conf. HAMILTON, ALEXANDER; MADISON, JAMES y JAY, JOHN, *The Federalist Papers*, New York, 1961, p. 467. Para una indagación histórica sobre el proceso en su conjunto, ver CABRERA ACEVEDO, LUCIO, *El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005.

(13) 5 U.S. 137 (1803).

(14) V. CLINTON, ROBERT L., “Precedent as Mythology: The Case of *Marbury v. Madison*”, en *Supreme Court Historical Society Yearbook*, Washington, D.C., 1989, p. 78.

(15) Conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., ob. y t. cit.

federalista, estaba por concluir su mandato. El Congreso autorizó al Ejecutivo a nombrar jueces de paz para el Distrito de Columbia (la capital de los Estados Unidos). Así, el presidente saliente aceleró las designaciones antes que jurara su sucesor Thomas Jefferson, del partido demócrata-republicano, lo que se llamó "los nombramientos de medianoche".

Llega el momento de transferencia del poder, a comienzos del mes de marzo, sin haberse alcanzado a despachar el nombramiento del Sr. William Marbury. El perjudicado solicitó entonces el nombramiento al nuevo Secretario de Estado James Madison. Frente a su negativa, Marbury interpuso acción de "mandamiento judicial" ("mandamus") ante la Corte Suprema, en los términos de la Ley Judicial del año 1789.

Sin lugar a dudas, el caso se desenvolvió en un ambiente políticamente muy cargado, de cambio de titularidad del Ejecutivo y del Congreso (del bando federalista al anti-federalista). La causa insumió casi dos años de tramitación, en medio de acusaciones y de pedidos de juicio político contra el "Chief Justice" Marshall, último Secretario de Estado de Adams, ferviente partidario federalista y quien había accedido a la Corte fruto también de un "nombramiento de medianoche".

En este cuadro, Marshall dicta su pronunciamiento, utilizando una lógica impecable en el marco del método deductivo. Formula tres interrogantes cruciales y sucesivos, a modo de *silogismo*.

- Primeramente, se pregunta si el Sr. Marbury tenía derecho al nombramiento. A ello contesta afirmativamente, puesto que había sido propuesto por el Presidente de los Estados Unidos, se le había otorgado el respectivo acuerdo senatorial y colocado el sello nacional. No se había comunicado debidamente ese nombramiento, pero ello no podía perjudicar al título judicial en sí mismo.
- La segunda cuestión era más bien procesal. Si tenía derecho a ser designado, ¿tenía alguna acción? Obviamente, el ordenamiento jurídico no podía permanecer impávido frente a una flagrante injusticia, máxime que, según el derecho común, "where there is a right, there is a remedy" ("donde hay un derecho debe haber un remedio").
- Ante esta nueva contestación afirmativa, Marshall se pregunta entonces si esa acción era el "mandamus" que había interpuesto Marbury. Aquí contesta negativamente. Si bien la ley judicial autorizaba deducir esa acción, lo hacía extendiendo la jurisdicción originaria de la Corte Suprema que, tanto en los Estados Unidos como luego en la Argentina, está delimitada por la propia Constitución. Por tanto, correspondía rechazar la acción de mandamiento judicial planteada.

Muchas observaciones se han hecho a este fallo. La principal es que so color de argumentos superficialmente lógicos, Marshall sacrificó a un correccionario político, a fin de no antagonizar a los poderes oficiales recién instalados de signo contrario.

Sin embargo, Marshall reservó para el poder judicial federal, bajo el ropaje de esa aparente "claudicación", el arma más poderosa que hoy día tienen los jueces: la declaración de inconstitucionalidad de una norma.

3. ENFOQUE PRÁCTICO DEL CASO

1. Evidentemente, el conflicto aquí suscitado era de naturaleza política. ¿Correspondía al Tribunal intervenir? ¿Podía decir que era una "cuestión política no justiciable"? ¿Cabe tal aseveración en el contexto de la jurisdicción originaria, cuando no hay otro tribunal apto a donde acudir?

2. ¿Debió excusarse Marshall? Fue hasta el final del gobierno de Adams su secretario de Estado, oficina que no había despachado el nombramiento (los historiadores señalan al hermano de Marshall como culpable del error administrativo. Por lo demás, como dijimos, Marshall también había sido un "nombramiento de medianoche" y activo partidario federalista.

3. La Corte americana fue renuente en lo inmediato a seguir invalidando leyes federales, tan es así que la próxima declaración de inconstitucionalidad de acciones federales va a ser pronunciada en 1857 (es decir, cincuenta y cuatro años después) en "Dred Scott v. Sanford" (16). Esta medida inicial, ¿es reconocible hoy día en algunos de los principios que gobiernan al control judicial de constitucionalidad?

4. Con este y otros fallos, Marshall se transformó en el juez más trascendente que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos. La exhibición permanente que aloja el edificio de la Corte americana lo tiene en una estatua gigantesca, con textos en dorado de sus principales decisiones. ¿Recuerda Ud. algún juez de la Corte Suprema argentina —o, para el caso, de cualquier otro país— que haya logrado obtener tal prestigio a lo largo de la historia?

5. Muchos alumnos preguntan en clase por la suerte del Sr. Marbury. La respuesta es ésta: "El propio William Marbury jamás recibió su nombramiento. Luego de iniciar su causa ante un tribunal federal de distrito, una serie de demoras procesales ocasionaron que el reclamo excediera el plazo legal de cinco años dentro del cual se aplicaba su nombramiento y finalmente la causa fue desestimada por abstracta" (conf. Burt, Robert A., "Constitución y conflicto", Buenos Aires, 2000, p. 186).

4. LOS GRANDES SISTEMAS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA

Con el correr del tiempo, el sistema de contralor constitucional inaugurado por la sentencia de "Marbury" logró difundirse a otros países.

(16) 60 U.S. 393. Nunca debemos olvidar que "por definición, controlar al poder es un acto de poder". V. VALADÉS, DIEGO, *El Control del Poder*, Buenos Aires, 2005, p. 17.

Así, hacia 1887 nuestra Corte Suprema admitió la institución en el caso "Sojo" (17).

Empero, para fines de la I Guerra Mundial (1918), se empezaron a esbozar otros esquemas. Parecía que en ciertas situaciones límite—como las atravesadas en el escenario europeo— el control difuso no era suficiente.

Excesiva burocratización de los jueces ordinarios (18), necesidad de una mayor concientización y especialización constitucionales (19), recelo en los magistrados comunes: diversos factores llevaron a que se diseñara una ruta alternativa para el control.

Así, se introducen en Checoslovaquia (febrero de 1920) y en Austria (octubre de 1920) sendos "Tribunales Constitucionales". La inspección de constitucionalidad ya no estaría a cargo de cualquier juez de cualquier instancia, sino que estaría localizada en una corte especial (control concentrado) (20).

Demás está decir que estas experiencias sufrieron el deterioro que implicaron los hechos desencadenantes de la II Guerra Mundial. Sin embargo, terminado este conflicto, muchos estados europeos abocados a la tarea de reconstrucción institucional volvieron a adoptar a los "tribunales" o "cortes constitucionales" como modelo.

La ley fundamental de Bonn de 1949, la reforma constitucional italiana de 1956 (21), y con mayor proximidad en el tiempo la constitución española de 1978 y la revisión constitucional portuguesa de 1982 todas se mostraron proclives en aceptar el modelo de una "jurisdicción constitucional" específica.

Cabe destacar que en los últimos años ha sido el diagrama que mayor adhesión ha concitado, como lo revela la constitución guatemalteca de 1985, la colombiana de 1991, las sudafricanas de 1993 y de 1996, la rusa de 1993, entre muchas otras.

La premisa básica sobre la que se asienta el control difuso es la potestad de cualquier juez ordinario de "decir el derecho", incluido claro está el constitucional. Dicha actividad, empero, se da en el concierto de un "caso" o "controversia"

(17) Fallos: 32:120. Sobre el caso "Sojo", ver, entre otros, FAYT, CARLOS S., *Supremacía constitucional e independencia de los jueces*, Buenos Aires, 1994, ps. 64 y sigtes.

(18) V. SCHWARTZ, HERMAN, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, Chicago, 2000, p. 23.

(19) V. SCHWARTZ, HERMAN, ob. y p. cit.

(20) V. FAVOREU, LOUIS, *Los Tribunales Constitucionales*, Barcelona, 1994, p. 15.

(21) V. CELOTTO, ALFONSO, *El Derecho juzga a la política (La Corte Constitucional de Italia)*, Buenos Aires, 2005. Ello no impide que en el derecho comparado existan sistemas mixtos, u otros en donde coexista el esquema difuso con el concentrado como el peruano. Ver sobre este último punto GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO, "La jurisdicción constitucional en Perú", en GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO, y FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, *La jurisdicción constitucional en Iberoamérica*, Madrid, 1997, p. 834. Algunos autores van más allá y avizoran hoy en día una confluencia global entre ambos modelos. Ver FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, 2004.

concreta, en donde la parte solicita a modo de excepción o de defensa la inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria. Ese control en el caso concreto hace que los efectos generalmente también se circunscriban a la causa.

Por el contrario, en la variante concentrada, hay dos caminos. Por un lado, existe el control abstracto, que puede ser iniciado sólo por determinados órganos del poder. Por el otro, en las contiendas en donde exista un asunto constitucional a dirimir, el planteo es elevado al Tribunal especializado para su consideración.

5. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A NIVEL FEDERAL EN ARGENTINA

Argentina en el plano federal muestra un sistema jurisdiccional difuso para controlar la constitucionalidad de las normas, de acuerdo con los lineamientos del derecho sentencial norteamericano.

De manera muy esquemática (22), trazaremos sus principales características:

1) En cuanto al sujeto habilitado para incoar el control, se da prioridad a la legitimación activa ("standing to sue") al perjudicado o afectado directo por una norma presuntivamente inconstitucional.

La incorporación de la acción de amparo colectivo por el segundo párr. del art. 43 permite ampliar la nómina de legitimados activos—en estos supuestos— a la Defensoría del Pueblo (art. 86, C.N.) y a las organizaciones no gubernamentales que propendan a esos fines, amén del Ministerio Público consagrado por el art. 120 de la Ley Fundamental.

2) Ello implica que el control se verifica en el marco de un "caso" o "contienda" concreta, en donde la parte debe pedir al juez la inconstitucionalidad del precepto que dice perjudicarlo. Se escatima al juez poder ejercer el control de oficio, salvo cuando está en tela de juicio la competencia del propio tribunal, o lo establezca puntualmente la ley (como lo hace la ley 23.098 de "habeas corpus"). A partir del caso "Banco Comercial de Finanzas" de 2004, la Corte ha sido proclive a admitir el contralor de oficio en términos más generales (ver Capítulo IV).

3) Teóricamente, desde la óptica del art. 116 C.N., el objeto de la inspección debería ser amplio, pues la norma refiere el conocimiento y decisión "de

(22) Una explicación detallada puede hallarse en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, t. I-A, Buenos Aires, 2000; asimismo, en BIANCHI, ALBERTO E., *Control de Constitucionalidad*, Buenos Aires, 2002. Ello, sin perjuicio de reconocer que el sistema argentino puede mostrar aristas mixtas. V. CARNOTA, WALTER F., "La mixtura del control de constitucionalidad argentino", en "Revista de Derecho" número 1, Montevideo, 2006, ps. 43 y sigtes.

todas las causas" bajo la Constitución. Empero, nuestra Corte —siguiendo las aguas de otros Tribunales en el mundo— se plegó a la doctrina de las "cuestiones políticas no justiciables" ("political questions"). Esta tesis sostiene que ciertos temas que muestran conflictos entre los poderes del estado deben ser resueltos por el proceso político (v.gr. el Presidente o el Congreso), y no por el poder judicial. Se ha elaborado así por vía pretoriana una larga lista de asuntos en los que la judicatura se autoinhibe de entender (p.ej. la determinación de la necesidad de la intervención federal a una provincia en los términos del art. 6º C.N., o la declaración de guerra a un estado extranjero).

Debe recalcar, en lo atinente al sistema de derechos humanos, que no sólo debe verificarse el control cuando están en juego los llamados derechos de primera generación (los clásicos civiles y políticos), sino también los de segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera generación (ambiente, protección al consumidor, etc.) (23).

4) Suele decirse que el camino procesal a recorrer es por "excepción", puesto que en el contexto de un pleito una parte agraviada esgrime la incompatibilidad de una norma inferior con la Constitución. Pero si bien nuestro sistema no prevé en especial las "acciones puras de inconstitucionalidad", algunos remedios procesales —como el amparo o la acción declarativa de certeza— suscitan verdaderos "procesos constitucionales", con lo cual también —dentro de un marco limitado— podría aseverarse que hay control de constitucionalidad por acción.

5) Finalmente, en lo que respecta a los efectos del control, debe quedar bien en claro que la declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma en cuestión, sino tan sólo la inaplica para el caso concreto. El efecto, pues, en nuestro sistema, no es derogatorio o "erga omnes", sino "inter partes" (para quienes han participado del proceso). Sin perjuicio de ello, el impacto de las más recientes decisiones de la Corte (como las adoptadas en materia de pesificación y de jubilaciones) puede conmover esta regla, y llevar a pensar que la ejemplaridad excede al caso (24).

6. PROBLEMAS DE TEORÍA CONSTITUCIONAL QUE ARROJA EL CONTROL JUDICIAL: ¿HAY UNA "DIFICULTAD CONTRAMAYORITARIA"?

Algunos autores, sobre todo dentro de la doctrina constitucional norteamericana, se han preguntado incisivamente por la legitimidad democrática del instituto del control judicial ("judicial review").

(23) V. CARNOTA, WALTER F., "Nuevos matices del control de constitucionalidad en materia de derechos humanos de segunda y de tercera generación", en ARMAGNAGUE, JUAN FERNANDO, (Director) y CARNOTA, WALTER F., (Coordinador), *El Control de Constitucionalidad en el Derecho Público y Privado*, Córdoba, 2005, ps. 89 y sigtes.

(24) Con relación a los efectos "erga omnes" en las acciones de amparo colectivo, ver MARANELLO, PATRICIO A., "Los efectos erga omnes en las sentencias de las asociaciones de consumidores y usuarios", LA LEY, del 26/5/99, p. 8.

En efecto, en una sociedad democrática las decisiones son adoptadas por los representantes de la mayoría del pueblo, quien ha elegido al Presidente y al Congreso.

Dichos órganos políticos toman determinados cursos de acción presumiblemente en concordancia con esas aspiraciones mayoritarias. Sin embargo, muchas veces esos actos (una ley, un decreto) emanados de sujetos investidos claramente de legitimidad democrática vienen a ser impugnados en los tribunales. Su inconsistencia constitucional viene a ser proclamada por los jueces que, en la mayoría de los casos, son funcionarios designados y no electos por el voto popular.

Se presenta así lo que se ha denominado "la dificultad contramayoritaria".

El autor que más estudió la cuestión fue Alexander Bickel. En su libro *"The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics"* (25) publicado en el año 1962, Bickel argumenta a favor de la restricción que los jueces deben tener al ejercer sus facultades revisoras. La legitimidad de los magistrados judiciales es más bien indirecta, y deben ser prudentes en no interferir indebidamente en el proceso político. De lo contrario, los sentenciantes estarían inculcando sus propios valores por sobre los de la comunidad.

Otro autor que investigó el tema fue John Ely. En su obra *"Democracy and Distrust"* (26), este autor parte de la premisa de Bickel en cuanto a la alegada dificultad contramayoritaria. Empero, acepta la "judicial review" en tanto y en cuanto el juez se erige en una especie de referí institucional, cuya misión es asegurar la estabilidad y permanencia del proceso democrático.

7. ¿NULIDAD O DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL? JURISPRUDENCIA: EL CASO "FAYT"

-I-

1. El 19 de agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una acción declarativa de certeza planteada por parte de uno de sus propios jueces, el doctor Carlos S. Fayt, tendiente a declarar la nulidad del art. 99, inc. 4 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma de 1994.

Cabe puntualizar que la decisión allí recaída ha merecido diversas interpretaciones por parte de la doctrina de derecho constitucional, algunas favorables y otras bastante críticas por cierto.

(25) V. BICKEL, ALEXANDER, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, Indianápolis, 1962.

(26) V. ELY, JOHN HART, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Cambridge, Massachusetts, 1980.

La relevancia del pronunciamiento estriba en que por primera vez nuestro más Alto Tribunal declaró la "nulidad" (léase invalidez constitucional o declaración de inconstitucionalidad) de una cláusula agregada por un proceso revisor. Se alejó así de su línea jurisprudencial tradicional—representada por la causa "de Guerrero" (27)—por la cual la temática de la reforma constitucional era considerada como una "cuestión política no judicial" y por tanto exenta de contralor.

2. Dentro de ese orden de ideas y de experiencias, la mayoría de la Corte (el juez Petracchi se excusó y el juez Bossert escribió una disidencia parcial) resolvió el pleito de manera análoga a como lo había hecho la juez de primera instancia. Eligió apartarse del criterio, en cambio, seguido por la Cámara de Apelaciones para la cual la disposición en crisis no era aplicable al actor por vulnerar sus derechos adquiridos.

-II-

3. Parece sumamente compartible un enfoque jurisprudencial que sea renuente a aceptar "zonas" o "islas" detraídas a la inspección constitucional. Tenemos muy en claro que desde el art. 116 de la C.N. (lo que hemos denominado "interpretación desde la Constitución"), la norma de base imputa al poder judicial federal (cuya cabeza es obviamente la Corte Suprema) "el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución". Hemos entendido que la norma no distingue en si la litis es de carácter político, o para el caso económica, o social, o artística o cultural. Pero ese abordaje amplio, proclive al control (después de todo, la esencia de la democracia son los controles, a los que no hay que temerles), no debe llevar a los jueces—en especial, a los de la Corte, y máximo cuando uno de sus miembros es quien acciona— a nulificar decisiones que han sido adoptadas por el poder constituyente derivado o reformador.

4. Sin duda, el argumento central que esgrimió la pluralidad del Tribunal fue que la mentada preceptiva afectaba la inamovilidad de los magistrados (fijada en el ex art. 96, actual 110 constitucional), sin que dicho asunto fuera objeto de habilitación en el temario o "agenda" de la reforma establecido por la ley 24.309.

5. Como se recordará, dicha ley en el famoso "Núcleo de Coincidencias Básicas", fruto de los acuerdos políticos de los Pactos de Olivos y de la Rosada, art. 2º, incs. H), I, y J, estipulaba aspectos a ser reformados de nuestro servicio de administración de justicia, que incluían la propuesta, designación y remoción de magistrados federales.

De manera puntual, sin embargo, no se había incluido la modificación del sistema de inamovilidad, ni se mencionaba específicamente al ex art. 96.

(27) Sentencia del 20 de septiembre de 1963, Fallos: 256:556.

6. Por su parte, el art. 5º de esta legislación ordenaba la votación "en bloque" (por la afirmativa o por la negativa) del referido paquete contenido en el apodado "Núcleo...", y el art. 6º fulminaba como "nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida en los arts. 2º y 3º de la presente ley de declaración". Precisamente, esa sanción es la que invoca la mayoría como eje vertebral de su decisorio (conf. consids. 10 y 16).

-III-

7. Las apuntadas reflexiones sirven de introducción para el siguiente trabajo de análisis del caso, sobre la base de lo hasta aquí estudiado:

8. En efecto, la Corte abandona su propio derecho judicial que estigmatizaba a la reforma constitucional como "cuestión política no justiciable" para entrar al fondo del asunto. ¿No es la reforma un tema a ser dirimido por los poderes políticos? ¿No se violenta la línea divisoria entre poder constituyente—aunque sea derivado— y poder constituido? ¿No se están dejando de lado las premisas fundantes de la constitución racional normativa o formal (escritura, rigidez, suprallegalidad) para entrar en un modelo de peligrosa flexibilidad?

9. Recuértese que la reforma constitucional de 1994 fue una de las que más consensos generó dentro de nuestra historia institucional, como que fue avalada por partidos políticos de las extracciones más diversas. ¿No fue la decisión del Tribunal un acto "contramayoritario"? ¿Quién representa cabalmente las mayorías: el Congreso, la Asamblea Constituyente o la Corte Suprema? (28).

10. ¿Se siguieron en el caso las clásicas técnicas de interpretación? Si fue así, cuáles y con qué alcance. ¿Se recurrió a la armonía o compatibilización (interpretación sistemática)? Por lo demás, ¿se está interpretando la ley (24.309) o la Constitución?

11. ¿No se dice que la declaración de inconstitucionalidad es la "ultima ratio"? ¿No es una sanción institucionalmente excesiva la nulificación de un artículo reformado?

12. ¿Podían intervenir el resto de los jueces del Tribunal en un pleito incoado por uno de sus componentes? Al tratarse de colegas del mismo Tribunal colegiado, ¿no les hubiera correspondido excusarse de acuerdo con la ley procesal, como hizo el doctor Petracchi?

(28) Una decisión evidentemente "contra-mayoritaria" puede advertirse en la adoptada en el caso de las elecciones presidenciales de 2000 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. V. CARNOTA, WALTER F., "Bush vs. Gore". La Corte Suprema de los Estados Unidos elige un Presidente, LA LEY, 2001-A, 394; ídem, DERSHOWITZ, ALAN, *Supreme Injustice (How the High Court Hijacked Election 2000)*, New York, 2001; asimismo, BUGLIOSI, VINCENT, *The Betrayal of America (How the Supreme Court Undermined the Constitution and Chose our President)*, New York, 2001.

13. ¿Cuál es el efecto de la declaración de "nulidad"? ¿Por qué decimos que "nulidad" equivale a "inconstitucionalidad"? ¿Le parece ello correcto, o son dos categorías conceptuales distintas? ¿Queda el precepto atacado derogado? ¿Beneficia a los otros jueces federales con 75 años de edad? ¿Deben retirarse, o iniciar una acción declarativa, o no hacer nada?

14. ¿Cómo se inscribe la decisión a la que se arribó en este litigio con otras adoptadas por la misma Corte en la década de los noventa? Resulta provechosa la lectura del trabajo de Sabsay, Daniel Alberto publicado en el "Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional", núm. 3 (año 1999), editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.



CAPÍTULO IV

CONTROL DE OFICIO DE CONSTITUCIONALIDAD

SUMARIO: 1. Introducción. Su marco científico. — 2. Caracteres generales. — 3. Análisis evolutivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diferentes períodos o etapas. a) Período de necesidad justificatoria. Desde la instalación del Tribunal hasta 1941. b) Período negatorio con excepciones. Desde 1941 a 1984. Caso: "*Ganadera Los Lagos S.A.*". c) Período permisivo minoritario. Desde el año 1984 al 2001. Voto de los doctores Fayt y Belluscio en la causa "*Inhibitoria planteada por el juzgado de instrucción militar N° 50*" y "*Peyrú; Osvaldo J. s /apelación*". d) Período permisivo mayoritario. Desde 2001 hasta la actualidad. — 4. Declaración oficiosa. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN. SU MARCO CIENTÍFICO

Si nos detenemos un instante en todas las temáticas más significativas de la ciencia jurídica, y nos abstraemos de nuestra materia específica, sea ésta penal, laboral, civil, comercial, contenciosa administrativa o tributaria, notaremos que además de ciertos principios y reglas esenciales comunes a todas, la Constitución es la base jurídica de las materias mencionadas, como una especie de rueda de bicicleta, donde la llanta sería la Constitución y los rayos las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, acordadas, etc..., regulatorias de las áreas citadas.

Todo lo que no está dentro de un ordenamiento normativo —siguiendo la corriente legalista— o deriva de éste, está fuera del Estado de Derecho. Pero hoy existe una noción básica aún más importante y significativa que surgió en el siglo XX, que denota que todo lo que no está regulado por la Constitución o sirve como norma fundante de las normas, está fuera del estado constitucional del derecho, circunscribiendo aún más los derechos y obligaciones de los gobernantes y de sus ciudadanos.

Para que se respetada y se cumplan las premisas enunciadas tenemos un test, denominado "control de constitucionalidad". Pero para comenzar a elaborar dicho ritual jurídico, debemos establecer una escala de valores o pirámide normativa, con el fin de conocer con exactitud la jerarquía de las reglas jurídicas de un estado —que no es igual en todos países—. A esto lo llamamos "Supremacía constitucional o supremacía de la constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional", que ya hemos examinado *supra*.

En esta temática, se han registrado innovaciones, con las reformas de la década del 90 en América Latina, como la República Argentina (1994), que en su art. 75 inc. 22 ha permitido compartir la cima de la pirámide con once instrumentos internacionales sobre derechos humanos, otorgándole jerarquía constitucional. A partir de allí la figura piramidal cambia para transformarse en un trapecio, solamente en materia de derechos humanos.

Al respecto, los poderes constituidos no pueden desconocer o contradecir el juicio de comprobación efectuado por los constituyentes según el cual los tratados a los que se otorgó jerarquía constitucional no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos: art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. Los tratados con jerarquía constitucional complementan las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución Nacional, aunque el constituyente no haya hecho expresa alusión a ella (1).

Que como se dijo el control de constitucionalidad es un instituto por demás importante, donde se registran los cambios más significativos tanto en el marco jurídico como político, porque este último fue atemperando su barrera ideológica en estos últimos años, donde la jurisprudencia ha sido más proclive a controlar las decisiones políticas o las llamadas "cuestiones políticas no justiciables", doctrina que está en un franco retroceso, avanzándose hacia el control judicial de toda norma sea ésta política o no.

Si bien la temática del control de constitucionalidad fue evolucionando hacia los sistemas concentrados, su declaración de oficio por parte del juez, es decir, sin petición de parte, es un asunto muy significativo, porque una cuestión es si el control lo hace un órgano determinado o todos los jueces y otra si tan solo se realiza a petición exclusiva de las partes o no es necesaria dicha petición.

Ello se enfrenta con una postura muy férrea en contra de la declaración de oficio, por resultar presuntamente violatoria de:

1. la división de poderes,
2. la defensa en juicio,
3. el principio de congruencia, y
4. la presunción de legalidad de los actos gubernativos.

Y justamente en este punto es muy importante tener en cuenta las vicisitudes del control de constitucionalidad de oficio, es decir, la evolución que ha tenido el tema en los últimos cinco lustros, donde se va experimentando un lento, creciente y significativo proceso de avance de dicha doctrina en los

ámbitos jurisdiccionales y, de modo especial y de decisiva trascendencia, un cambio fundamental en la tradicional e inveterada doctrina judicial negatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo veremos *infra*, seguramente impulsada por numerosos estudios y antecedentes elaborados por la opinión mayoritaria de constitucionalistas y de procesalistas (2).

2. CARACTERES GENERALES

La declaración de inconstitucionalidad de oficio debe entenderse aquella función del Juez ejercida dentro de una "causa", donde de los argumentos jurídicos —no fácticos— surge una clara inconstitucionalidad no planteada por las partes. Ello no puede admitir excepciones, atento el principio sostenido, ya desde 1864, en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores son los últimos intérpretes de la Constitución.

Y no implica fallar *extra petita* ni soslayar el principio de congruencia, en tanto el juez se limite a las cuestiones planteadas en el proceso, y para dilucidar la litis, sólo esta sujeta la selección del derecho aplicable a su concordancia con la Ley Fundamental. Todo ello sin olvidar que el control de constitucionalidad no es una concesión graciosa conferida a los jueces sino un deber que sobre ellos se cibe.

La declaración de inconstitucionalidad está sujeta a requisitos y a circunstancias que no se vuelven más rigurosas en el caso de que se actúe de oficio.

Para declarar inconstitucional de oficio una norma deben estar presentes los requisitos y los clásicos caracteres de nuestro sistema de control de constitucionalidad, como ser que la declaración de inconstitucionalidad es la "*ultima ratio*" del orden jurídico, como lo ha reiterado en numerosas oportunidades la Corte Suprema. De manera que los recaudos deben extremarse tanto como si hubiera sido pedida por una de las partes.

A nuestro criterio, la primera temática que deberá esclarecerse, es el fundamento que la corriente negatoria encuentra en el art. 2° de la ley 27 promulgada el 16/10/1862, donde se establece que la autoridad judicial "...nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte..."

Aquí lo que se quiso limitar es la actuación del juez dentro de una causa, es decir, la jurisdicción —esta facultad decisoria y compulsiva que ostentan los justiciables— comienza y termina en la causa, "dentro de ella todo, fuera de ella nada". Es por dicho motivo que la declaración de inconstitucionalidad de oficio no puede ir más allá de la controversia entre el actor y el demandado —por más que haya muchos o pocos de un lado y del otro—, con una ligazón fáctica y jurídica inquebrantable.

(1) CSJN *in re*: "Monges, Analía M. c. UBA. - resol. 2314/95". Fallos: 319:3148. Ref.: Constitución Nacional. Magistrados: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López. Disidencia: Fayt, Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención: 26/12/1996.

(2) HARO, RICARDO, *El control de constitucionalidad*, Buenos Aires, 2003, p. 51.

Esto es muy diferente a decir que no procede la inconstitucionalidad de oficio porque no hubo petición de parte; por el contrario, si algunas de las partes omiten el pedido de inconstitucionalidad y la declaración sirve para esclarecer la búsqueda de la verdad jurídica objetiva del litigio, la inconstitucionalidad de oficio siempre procede.

3. ANÁLISIS EVOLUTIVO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIFERENTES PERÍODOS O ETAPAS

En el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte pueden señalarse cuatro períodos en torno al ejercicio del control de constitucionalidad:

- a) Período de necesidad justificatoria: Desde la instalación del Tribunal (1863) hasta 1941;
- b) Período negatorio con excepciones: Desde 1941 hasta 1984. Caso: "*Ganadera Los Lagos S.A.*".
- c) Período permisivo minoritario: Desde 1984 hasta 2001. Voto de los doctores Fayt y Belluscio en la causa "*Inhibitoria planteada por el juzgado de instrucción militar N° 50*" y "*Peyrú, Osvaldo J. s/apelación*".
- d) Período permisivo mayoritario: Desde 2001 en adelante. Caso "*Mill de Pereyra*" y "*Banco Comercial de Finanzas*".

a) Período de necesidad justificatoria. Desde la instalación del Tribunal hasta 1941

Desde la instalación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de enero de 1863 (3) hasta 1941 no hubo regla explícita sobre la necesidad de la "petición de parte" para el ejercicio del control. Dentro de este período encontramos fallos en los que la Corte había ejercido el control de oficio o bien había establecido el ejercicio del control como una obligación de los jueces.

En primer lugar, cabe recordar que en el año 1871 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "*Caffarena c. Banco Argentino de Rosario*" (4), admitió que estaba en la esencia del orden constitucional, que los tribunales tuvieran, no sólo la facultad, sino la obligación, de anteponer en sus resoluciones, los preceptos de la Constitución Nacional. Inmediatamente después fue resuelto el caso "*Vicente Casares e Hijos c. Sivori y Schiaffino*" (5), en el cual confirmó un fallo del juez de sección Manuel de Zavaleta, donde, sin requerimiento de parte, había ejercido el control de constitucionalidad.

(3) En el mes de septiembre de ese año se comenzó a editar la colección de los fallos de la Corte.

(4) Fallos: 10: 427 —1871—.

(5) Fallos: 11: 257.

Más tarde, en el caso "*Municipalidad de la Capital c. Isabel A. de Elortondo*" (6), admitió la declaración de inconstitucionalidad de oficio, pese a que la demandada no la había solicitado, respecto de la ley que afectaba su propiedad, limitándose a efectuar una interpretación distinta de la sostenida por la Municipalidad expropiante.

En los fallos citados, la Corte sentó en términos muy claros algunas reglas que permiten sostener su convicción acerca de la trascendencia del control y del deber de los jueces de ejercerlo. El Tribunal fijó como regla que es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se encuentran los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos.

b) Período negatorio con excepciones. Desde 1941 a 1984. Caso: "*Ganadera Los Lagos S.A.*".

En el segundo período, a lo largo de cuatro décadas (1941 a 1984), la Corte estableció que el control no podía ser ejercido de oficio, salvo cuando se trataba de ejercerlo para mantener su independencia como poder, o era necesario preservar la integridad del mismo.

La regla general fue establecida formalmente en el caso "*Ganadera Los Lagos*" (7), del año 1941. Allí la Corte Suprema expresó: "Que es condición esencial en la organización de la administración de justicia con la categoría de 'poder' la de que no le sea dado controlar por propia iniciativa de oficio los actos legislativos o los decretos de la administración. Para mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes sin provocar el desequilibrio de los tres poderes es indispensable que exista en el pleito, una cuestión que proporcione a los componentes del Poder Judicial la oportunidad de examinar, a pedido de algunos de los litigantes, si la ley o el decreto conforman sus disposiciones a los principios y a las garantías de la Constitución Nacional".

c) Período permisivo minoritario. Desde el año 1984 al 2001. Voto de los doctores Fayt y Belluscio en la causa "*Inhibitoria planteada por el juzgado de instrucción militar N° 50*" y "*Peyrú, Osvaldo J. s/apelación*".

En el tercer período, se mantuvo en la composición de la Corte la tesis prohibitiva del control de oficio, como regla, pero con disidencias. Tal fue el

(6) Fallos: 33: 162.

(7) Fallos: 190:142, LA LEY, 23-251.

caso de los Ministros Fayt y Belluscio en los precedentes "Juzgado de Instrucción Militar N° 50 de Rosario" (8) y "Osvaldo Peyrú" (9).

En el primero de los casos señalados, se había planteado un conflicto positivo de competencia entre un tribunal militar y un juez de instrucción de la Ciudad de Rosario, quien para fundar su competencia había declarado de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 108 inc. 2 del Código de Justicia Militar y el artículo 10 de la ley 23.049 (10). La posición mayoritaria de la Corte apoyada por el dictamen del Procurador General se pronunció por la competencia del tribunal y sostuvo que el control de constitucionalidad de oficio ejercido por el juez no era válido.

En el segundo caso mencionado "Peyrú, Osvaldo J. s/ apelación" se dijo que no es dable expedirse de oficio salvo si se exceden los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales. Esto fue apuntado por el voto de la mayoría; no obstante, y según su voto, Belluscio sostuvo que los jueces están facultados para declarar inconstitucionalidad de oficio.

Fayt concluyó que no afecta la presunción de legitimidad de los actos legislativos, ya que dicho instituto es meramente provisional —*iuris tantum*— y cede, en un sistema de control constitucional difuso, ante la comprobación y declaración de invalidez de las normas por el Poder Judicial. Cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad no implica una violación del derecho de defensa, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes con el pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso.

En el mismo sentido, los doctores Belluscio y Boggiano se pronunciaron en su voto en disidencia en la causa "Galeano c. Administración Nacional de Aduanas", sentencia dictada el 1° de junio de 2000 (11).

Allí se destaca la postura de los Doctores Fayt y Belluscio expresando que dicho control versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho y la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente —principio *iura novit curia*— incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución, aplicando en caso de colisión de normas la de mayor rango.

En la posición contraria a la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes se pronunció el doctor Moliné O'Connor, quien sostuvo "...que la declaración de inconstitucionalidad de oficio podría interpretarse como un avasallamiento en el derecho al autogobierno, perpetrado no por los poderes políticos, sino por el Poder Judicial" (12).

(8) Fallos: 306: 303, LA LEY, 1984-B, 426.

(9) Fallos: 310:1401.

(10) Adla, XLIV-A, 8.

(11) Fallos: 323: 1421.

(12) Seminario sobre jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado en 1999, en la Universidad Católica Argentina.

d) Período permisivo mayoritario. Desde 2001 hasta la actualidad

d.1) Caso "Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl y Pisarelo Angel c. Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contencioso administrativa".

Llegamos al caso "Mill de Pereyra", dictado el 27 de septiembre de 2001 (13). En la causa, los actores —magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes—, promovieron una acción contencioso administrativa con el objeto de obtener el reconocimiento de diferencias salariales en sus remuneraciones por entender que la falta de actualización de sus emolumentos, en períodos en los cuales había existido un alto proceso de inflación (1984-1988), afectaba la garantía de intangibilidad establecida en la Constitución Nacional.

El Superior Tribunal de Justicia Provincial, integrado por conueces, hizo lugar a la acción y declaró —de oficio— la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley nacional de convertibilidad (14) y de la ley provincial de consolidación de deudas del Estado. En concreto, la declaración oficiosa recayó sobre aquellas normas que vedaban la actualización monetaria a partir del 1° de abril de 1991.

La vencida interpuso el recurso extraordinario que fue parcialmente concedido. Con relación a los aspectos denegados, dedujo el pertinente recurso de queja.

El argumento recursivo consistió en que el Superior Tribunal Provincial había violado el principio de congruencia y el de defensa en juicio, pues la falta de discusión previa sobre las leyes de convertibilidad y de consolidación provincial motivó que se expidiera sorpresivamente sobre un tema que no había sido pedido y por ello no había sido objeto de debate, esto es, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes mencionadas.

El voto mayoritario examinó la validez de la ley de convertibilidad (en tanto suscitó cuestión federal), concluyendo que fue dictada por el legislador en ejercicio de la facultad de "hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras" (artículo 75 inc. 11, Constitución Nacional), no siendo válido asignar a la garantía constitucional de la intangibilidad una extensión tal que la coloque en pugna.

En cuanto al agravio referente a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, corresponde remitirse al voto de los jueces Fayt y Belluscio en el caso de Fallos: 306:303, donde se expresó que "no puede verse en la admisión de esa facultad la creación de un desequilibrio de poderes en favor del Judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se

(13) Fallos: 312: 2494; LA LEY, 2001-F, 891.

(14) Ley 23.928.

opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos, o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando contrarían una norma de jerarquía superior, lo que ocurre con las leyes que se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso" (considerando 5°).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja, se declaró procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se revocó la sentencia.

El voto en disidencia, de los Dres. Nazareno y Petracchi señaló que, de conformidad con antigua doctrina de la Corte, los jueces no están facultados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes.

Resumiendo la doctrina derivada del citado fallo de la Corte Suprema en autos "Mill de Pereyra" (15), si bien no implica la habilitación a los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley en cualquier supuesto, sí se los autoriza en situaciones muy precisas:

- a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como la "*ultima ratio*" del orden jurídico.
- b) cuando la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad;
- c) cuando la incompatibilidad sea inconciliable, o sea, cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones distintas que las constitucionales comprendidas en la causa;
- d) cuando su ejercicio no suponga en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta, lo que determina el carácter incidental de este tipo de declaraciones de inconstitucionalidad, o sea, que se ejerce sólo cuando es necesario remover un obstáculo que se interpone entre la decisión de la causa y la aplicación directa a ésta de la C.N.;
- e) cuando la declaración de inconstitucionalidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario para resolver el caso;
- f) cuando la declaración de inconstitucionalidad no tenga efecto derogatorio genérico.

Como sostiene Emilio Ibarlucía (16) se trata de requisitos y caracteres clásicos de nuestro sistema de control de constitucionalidad. En especial, la inconstitucionalidad debe ser manifiesta e indubitable y no debe quedar margen para resolver el caso sin tener que recurrir a esa declaración.

d. 2) "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra" del 19 de agosto de 2004, Fallos: 327:3117.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resolvió dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad dispuesta de oficio por la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial de Bahía Blanca respecto del decreto 2075/93. Señaló su validez y aptitud para reglamentar la ley 21.526, declarando que la acreencia del Banco Central de la República Argentina originada en el canje de imposiciones para Bonex con posterioridad a la liquidación, quedaba comprendida en la preferencia establecida en el artículo 264 de la ley concursal.

Para así decidir, y en lo que aquí interesa el a quo destacó que los jueces en resguardo del principio de división de poderes, no podían declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, ya que tal impugnación debía ser alegada y probada en juicio, lo que dijo, no sucedió en autos. Señaló asimismo, en cuanto a la aplicación del decreto y la ley que reglamenta, que si bien el artículo 12 de la ley 24.144, derogó la ley 22.529, el artículo 8° de esta última dispuso la ultra-actividad del aludido régimen al establecer la continuidad de su aplicación a las liquidaciones en curso al momento de la sanción de la ley.

Señala el recurrente, que si bien su parte no planteó la inconstitucionalidad de la norma, el Tribunal ha reconocido que resulta incompatible con el régimen del control de legalidad que ejerce el Poder Judicial, la omisión de pronunciamiento de cualquier magistrado sobre las cuestiones constitucionales que se susciten en los pleitos que debe resolver.

Agrega que la norma en cuestión ya había sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal en fallo del 15 de julio de 1997, en el precedente B.490. L. XXVII, "Banco Sidesa S.A. s/ quiebra", por transgredir las garantías consagradas en el artículo 16 y 17 de la Constitución Nacional, y por lo tanto no existe obstáculo para que las partes lleven a conocimiento de la Corte la interpretación de otros tribunales que no coincidan con su doctrina; y para ello precisamente el régimen jurídico argentino ha previsto el correspondiente remedio federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el considerando 3 del voto mayoritario de los Dres. Petracchi (según su voto), Belluscio, Fayt, Boggiano, Vázquez, Zaffaroni y Highton de Nolasco, sostuvieron que si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la

(16) IBARLUCIA, EMILIO: "Control de oficio de constitucionalidad. Algunas precisiones sobre su procedencia", ED, 9/5/2002.

cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente —trasuntado en el antiguo adagio *iura novit curia*— incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (Fallos: 306:303, considerando 4° del voto de los jueces Fayt y Belluscio).

Doctrina fijada por la CSJN:

- 1) El Control de constitucionalidad en Argentina no se pronuncian en "abstracto" y solo se analiza el caso "concreto".
- 2) El examen de constitucionalidad de las normas es una cuestión jurídica y no fáctica.
- 3) Del antiguo adagio "*iura novit curia*" se desprende la obligación de los jueces de expresarse sobre el derecho existente en el litigio, aunque sea sin petición de parte, velando en todos los casos por la supremacía constitucional.
- 4) Efectuar el control de constitucionalidad de oficio no viola la división de poderes porque es una facultad exclusiva y primordial del juez declarar toda norma que se encuentre en contra de la Constitución sea a petición o no de las partes.
- 5) La presunción de validez constitucional de los actos administrativos cede cuando choca con una norma de jerarquía superior.
- 6) La defensa en juicio no se encuentra menoscabada por la declaración de inconstitucionalidad de oficio por ser un uso en el poder judicial analizar habitualmente normas no invocadas por las partes.

4. DECLARACIÓN DE OFICIO. RECAPITULACIÓN

En el presente capítulo reseñamos la evolución histórica de la jurisprudencia de la Corte en materia de declaración de inconstitucionalidad de oficio, y el significado que tiene el control de oficio y la defensa en juicio.

El paso posterior al control de constitucionalidad de oficio sin petición de parte es justamente la declaración misma de inconstitucionalidad, donde se deben decir los motivos que llevaron a efectuar un control de oficio. Esto no implica violar ningún principio constitucional pues es el juez quien considera que la norma es claramente contraria a la constitución y debe así declararlo, en el caso concreto y con efectos *inter partes*.

Como conclusión, podemos decir que la declaración de inconstitucionalidad de oficio resulta procedente e indispensable en el actual contexto jurídico, pues debido a que esta facultad no altera ninguno de los derechos y principios vertidos por la doctrina prohibetista, el juez está obligado a declarar toda norma jurídica que considere inconstitucional, dado que:

- 1) Si bien es cierto que para declarar la invalidez de una norma es preciso que exista caso concreto, de ahí no se sigue la necesidad de petición expresa de parte interesada.
- 2) Por el principio "*iura novit curia*" es posible el examen oficioso, porque el control de constitucionalidad requiere el análisis de una cuestión de derecho y no de hecho. La potestad del juez de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente incluye el deber de mantener la supremacía de la constitución (art. 31 de la C.N.) aplicando en caso de colisión, la norma de mayor rango.
- 3) Se desestima asimismo el argumento relativo a la violación del principio de división de poderes por considerar que la cuestión no difiere cuando el control se ejerce a pedido de parte.
- 4) El control de oficio no se opone a la presunción de validez de los actos de los poderes públicos, ya que esa presunción cede cuando el acto es contrario a la Constitución.
- 5) El control de oficio no afecta el derecho de defensa de las partes. Si así fuera debería descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma no invocada por ellas.

Y con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de oficio en las Provincias Argentinas (17) y la Ciudad de Bs. As. (18), podemos observar como algunas de ellas se separan del criterio federal, ya sea expresándolo en sus constituciones o a través de su jurisprudencia.

Esta separación que hacen algunas de las provincias argentinas nos parece realmente importante, puesto que puede ser el origen de un cambio rotundo y definitivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todo ello no debe perder de vista que la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma es algo excepcional y de hacerlo sólo lo será en casos puntuales, cuando la violación del principio de supremacía de la Constitución aparezca flagrante e indudable, no viole la división de poderes, ni la defensa en juicio de los derechos de ambas partes.

Para este último aspecto sería conveniente dar traslado a las partes para que puedan expresar libremente su opinión al respecto, sea ésta favorable o

(17) Art. 154 inc. 3 de la Provincia de Tierra del Fuego, arts. 9° y 132 de la Constitución de La Rioja; art. 9° de la Constitución de Neuquén, entre muchas otras.

(18) Arts. 14 y 15 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

desfavorable, para aventar esta última posible lesión. El pronunciamiento registrado en "Mill de Pereyra" (19), sirvió para que cada uno viera lo que quisiera ver: algunos sostuvieron que finalmente la Corte había acogido la inconstitucionalidad oficiosa, mientras que otros afirmaron que era un caso tangencial o marginal. Estas dudas interpretativas llevaron incluso a que uno de los jueces tuviera que explicar en la doctrina "ex post" las razones de su voto (20).

En cuestiones netamente jurídicas no encontramos obstáculo para la declaración de oficio. El campo resulta más restringido si son cuestiones de políticas: económicas, sociales, culturales, educacionales, etc. Esta facultad se achica dado que si libremente se concede, el juzgador estaría reemplazando a uno de los poderes políticos del estado, sea Poder Ejecutivo o Legislativo. Sólo así se salvan las objeciones que se han levantado contra un presunto "carácter contra-mayoritario" o de "déficit democrático" de la inspección de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial, al remontar su fundamento último al respeto de los derechos de las minorías y a la imparcialidad que debe contener el razonamiento judicial (21).

Para ello debemos tener en cuenta que el análisis de la cuestión sería tan solo al caso concreto y, cuando se ha desnaturalizado, alterado o quebrantado algún derecho o principio constitucional, en estos casos el juez tiene la obligación de seguir el derecho y no la ley inconstitucional. Todo ello sin tener la intención de sustituir ningún poder sino de controlar y respetar la Constitución, actuando como un juez y no fijando políticas de estado generales, cuya aplicación resultan de mérito y conveniencia política por los otros poderes del estado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Verbitsky" (Fallos: 328:1146) resaltó que hay una muy fina línea que se torna borrosa entre la evaluación de la "oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria, y menos aún, su política criminal en la parte que le compete" (consid. 25), y lo allí resuelto. Es que el Alto Tribunal ha actuado como "una Corte Constitucional" que "fija pautas y establece estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política en cuestión" (consid. 26). El "self-restraint" que mostraron las jurisdicciones superiores provinciales ha dado paso a un activismo que se da en un contexto, justo es reconocerlo, de desertión de los poderes políticos frente a un problema humano y jurídico de envergadura (22).

(19) Fallos: 324:3219.

(20) CARNOTA, WALTER: "La inconstitucionalidad de oficio una cuestión saldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", El dial.com, agosto de 2004.

(21) Véase GARGARELLA, ROBERTO, "Control de constitucionalidad", en AA.VV., *Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2004, ps. 633 y sigtes.

(22) CARNOTA, WALTER: "Un problemático supuesto de "habeas corpus colectivo" (Nota al fallo "Verbitsky"), el dial.com, mayo de 2005.

Por todo lo expuesto no sólo el control de constitucionalidad de oficio no choca contra la división de poderes, sino por el contrario lo hace aún más fuerte, robusteciendo su facultad implícita y exclusiva en el control de constitucionalidad de oficio, sin menguar el sistema republicano y priorizando la aplicación del derecho por sobre la ley y lo pedido por las partes.

Todo ello en defensa de la más sagrada de las normas, que es la Constitución, donde los jueces son sus guardianes en forma permanente sin poder tener excusa alguna para no resguardarla, porque en ella radica el verdadero límite del poder a los otros dos poderes ya que esa es la esencia de la división de poderes. Como nos recuerda Hans Kelsen (23) "....La función política de la Constitución es la de poner límites jurídicos al ejercicio del poder..." y, "...como toda norma, también la Constitución puede ser violada por aquellos que deben cumplirla...".

(23) KELSEN, HANS, *El defensor de la Constitución*, Madrid, 1995.

PARTE SEGUNDA

DINÁMICA CONSTITUCIONAL

Todos X Derecho

CAPÍTULO I

REFORMA CONSTITUCIONAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Las clases del poder constituyente. — 3. Titularidad del poder constituyente. Ejercicio. — 4. De nuevo sobre los límites. — 5. Procedimiento. — 6. Las reformas de la constitución nacional. a) La llamada reforma de 1860. b) La reforma de 1866. c) La reforma de 1898. d) La reforma de 1957. e) La reforma de 1994. f) Quid de una nueva reforma futura.

1. INTRODUCCIÓN

Los vientos de reforma constitucional (1) se sienten en muchas latitudes. Por un lado, muchos países de América Latina intentan elevar su calidad de vida institucional y mejorar sus constituciones (2), cuestionando severamente a los esquemas autoritarios del pasado (3). Los esfuerzos pre-constituyentes peruanos iniciados en 2001 (4) y la reciente revisión constitucional chilena de 2005 se inscriben —sin dudas— en ese movimiento.

Por el otro, Estados que hasta hace poco tiempo no habían tenido que lidiar con el fenómeno del terrorismo, se encuentran debatiendo la necesi-

(1) Ver exposición de CARNOTA, WALTER F., en el Encuentro de las Asociaciones Argentina, Chilena y Peruana de Derecho Constitucional, y de la Academia Boliviana de Derecho Constitucional, Lima, agosto de 2006. Para un modelo de proceso constituyente democrático, véase PEREZ ROYO, JAVIER, *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid y Barcelona, 2005, ps.120/121.

(2) Se ha afirmado con razón que "los procesos de reforma constitucional en los países de América Latina, en general, y en el Perú, en particular, se han realizado, hasta no hace mucho tiempo, sin observar el procedimiento establecido por las propias constituciones. Sin embargo, esta situación se ha ido revirtiendo paulatinamente en la medida que los Tribunales Constitucionales han asumido, en tanto guardianes de la Constitución, una actitud vigilante a fin de que los procesos de reforma constitucional se realicen dentro del marco establecido de los límites formales y materiales". V. LANDA, CÉSAR, "La reforma de la Constitución desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en *Justicia Constitucional*, núm. 1, Lima, septiembre de 2005, p. 150. Claro está que debe evitarse caer en la "contrarreforma", como ocurrió en Argentina con el caso "Fayt". V. CARNOTA, WALTER F., *Curso de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2001, p. 49; HERNÁNDEZ, ANTONIO M., *El 'caso Fayt' y sus implicancias constitucionales*, Córdoba, 2001.

(3) Las transiciones políticas son bi-direccionales, como bien reseña DE VERGOTTINI, GUISEPPE, *Las transiciones constitucionales*, Bogotá, 2002, p.177.

(4) V. Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú, Lima, 2001.

dad de incorporar o no institutos de emergencia en su texto constitucional, como acontece con los Estados Unidos en su realidad post 11 de septiembre.

En tal sentido, la polémica suscitada en 2004 entre los profesores Bruce Ackerman, de Yale (5), y Laurence Tribe, de Harvard (6), sobre la "constitución de la emergencia", es adecuadamente ilustrativa sobre el punto. Europa sigue trabajando sobre la hipótesis de una Constitución comunitaria. En todas partes, desde Perú y Chile, hasta la India e Irlanda (7), se plantea desde hace mucho tiempo el problema de los límites materiales o sustantivos del poder constituyente derivado o reformador (8): los valores intrínsecos del sistema, la identidad constitucional y el derecho internacional, a la hora de pensar en posibles revisiones constitucionales. España aborda la cuestión de género en la sucesión dinástica e Italia el perfil de su forma de estado tan especial. No hay un proceso unívoco de reforma, aunque hay una sola dirección debida: la que consolida al Estado democrático.

Desde la óptica del derecho argentino, cabe afirmar que la revisión constitucional de 1994 fue una de las que más consenso tuvo, visto que resultó aprobada sin exclusiones ni proscripciones de ninguna índole. El "re-escalafonamiento" del derecho internacional de los derechos humanos por conducto del art. 75 inc. 22 pareció validar institutos mucho más controversiales y menos pacíficos como los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada y la reelección presidencial inmediata.

Como sea, no es dable pensar en Argentina por el momento en una nueva reforma constitucional, pese a existir voces contrarias en la doctrina (9).

2. LAS CLASES DEL PODER CONSTITUYENTE

a) Poder constituyente originario

Existe un poder investido para "hacer" o "elaborar" la Constitución. Ese poder, que radica en el pueblo, es el **poder constituyente originario**. También se lo conoce como **primigenio, fundacional o revolucionario**.

(5) V. ACKERMAN, BRUCE, "The Emergency Constitution", en "The Yale Law Journal", vol. 113, ps. 1029 y sigtes.

(6) V. TRIBE, LAURENCE, y GUDRIDGE, PATRICK O., "The Anti-Emergency Constitution", en "The Yale Law Journal", vol. 113, ps. 1801 y sigtes.

(7) V. JACOBSON, GARY JEFFREY, "An unconstitutional constitution? A comparative perspective", en "International Journal of Constitutional Law", vol. 4, número 3, New York, Julio de 2006, p. 460.

(8) En su versión implícita. V. DIAZ RICCI, SERGIO, *Teoría de la Reforma Constitucional*, Buenos Aires, 2004, p. 657.

(9) V. FERREIRA, RAÚL GUSTAVO, *Sobre la Reforma Constitucional (Acerca de la necesidad de un nuevo momento constituyente para el Estado argentino)*, Buenos Aires, 2006. Asimismo, publicado en "Debates de Actualidad" (Revista de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional), núm. 196, Buenos Aires, diciembre de 2005 a junio de 2006, p. 37.

Debe reconocerse que dicha potestad es fundacional de un régimen constitucional determinado. Se ejerce en un momento dado y se agota. En esta etapa "genética" del Estado, el poder constituyente originario aparece formalmente ilimitado, más allá que los autores hayan querido encontrar límites de índole material en el valor justicia o derecho natural, o como ocurre en algunas constituciones en el análisis comparado, en el derecho internacional público.

b) Poder constituyente derivado

El **poder constituyente derivado** es en cambio el relativo a la capacidad para reformar o modificar la Constitución, de acuerdo con los procedimientos por ella fijados. Y esta competencia reconoce límites muy precisos, que son tanto los formales como materiales que se encuentran previstos en la Constitución originaria.

Bien señala Spota que el poder constituyente derivado es netamente jurídico, y está condicionado por lo que denomina la lógica de los antecedentes (10).

En el caso argentino, el procedimiento marcado y pautado por el art. 30 constitucional, que es netamente una norma de organización, dentro del elenco de reglas constitucionales.

c) Contenidos pétreos

Más allá de la literalidad del art. 30, un sector de la doctrina ha discernido la existencia de **contenidos pétreos**, que serían aspectos de la Constitución que por su valor en la estructura del Estado resultarían irreformables y permanecerían "eternos" (11). Esta categoría se relaciona con la distinción de "cuestiones de sustancia" (v.gr., esos contenidos), y "cuestiones de procedimiento" (el aludido art. 30), pero lo cierto del caso es que se trata de criterios emanados de la literatura constitucional especializada.

Resulta, finalmente, complicado conciliar las potestades de la Asamblea Constituyente referida por el art. 30 tantas veces citado con las facultades que el nuevo art. 75 inc. 22 concede al Congreso en materia de inclusión a la jerarquía constitucional y denuncia de tratados internacionales de derechos humanos.

d) Poderes constituidos

Los **poderes constituidos** son los creados en virtud de la propia Constitución. Desde los aportes de Locke y de Montesquieu, se reconoce una "división

(10) V. SPOTA, ALBERTO ANTONIO, *Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente*, Buenos Aires, 1993, p. 139.

(11) Nuestra Corte Suprema parece admitir la existencia de algunos de estos "contenidos pétreos" en la causa "ALITT c. Inspección General de Justicia" (sentencia del 21/11/06), cuyo considerando doce habla de "cláusulas inmutables" (arts. 1º y 33, C.N.).

de poderes", es decir, se procede a una distribución de las funciones del mismo, con la finalidad de que resulte menos opresivo para la población.

Clásicamente, se habla de "tres poderes" o de "tres departamentos del poder" que titularizan las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

3. TITULARIDAD DEL PODER CONSTITUYENTE. EJERCICIO

La dogmática constitucional expresa que el poder constituyente originario se encuentra emplazado en el pueblo, o sus representantes. Se distingue así el titular de quien efectivamente ejerce u opera ese poder, que es generalmente una convención o asamblea constituyente que actúa en su nombre.

Al respecto, señala Sagüés que "la diferenciación entre titular y ejercitador del poder constituyente tiene sentido en la medida en que el primero interviene de algún modo decisivo en el proceso de elaboración de la constitución. De lo contrario, aquella distinción puede ser una suerte de mentira piadosa, creando la ilusión —para el titular— de ser una pieza vital en el proceso constituyente, cuando en realidad sólo el ejercitador cumplió tal papel. Según las actuales pautas del legitimismo democrático, en verdad, lo más correcto es que el pueblo no solamente elija a quienes van a elaborar el texto constitucional, sino que además lo apruebe, una vez redactado, mediante un referéndum o plebiscito. Solamente así podría afirmarse, con bastante exactitud, que la constitución es imputable al pueblo, y producto de su voluntad" (12).

4. DE NUEVO SOBRE LOS LÍMITES

Desde un andarivel estrictamente teórico, pues, el poder constituyente originario es formalmente ilimitado. No hay condicionamientos jurídicos en su accionar.

Por el contrario, el poder constituyente derivado tiene las restricciones que fija la norma respectiva. Si bien nuestro art. 30 estatuye que la Constitución puede reformarse total o parcialmente, ello no ha impedido —como ya se vio— a la doctrina discernir la existencia de contenidos pétreos, aristas fijas en el derecho natural, la costumbre y el derecho internacional que serían insusceptibles de cambio.

5. PROCEDIMIENTO

Consigna el art. 30 constitucional lo siguiente, reforzando el carácter rígido de nuestra Ley Suprema, e ideando una mecánica compleja de reforma:

(12) V. SAGÜÉS, NÉSTOR P., *Teoría de la Constitución*, Buenos Aires, 2001, p. 285 (énfasis en el original).

"La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto".

Debe distinguirse:

- Una etapa declarativa de la necesidad de la reforma (o preconstituyente), a cargo del congreso nacional.
- La reforma constitucional propiamente dicha, en cabeza de una convención convocada a ese efecto.

Explica Gelli que "la Convención puede reformar una, más o ninguna de las disposiciones que el Congreso declaró necesarias de enmendar. Si la Convención fuese más allá de lo declarado por el Congreso, esa cláusula sería nula o inconstitucional, aunque nada dijera sobre ello la ley declarativa, pues carecería del antecedente necesario. Aunque la vulneración de la voluntad del Congreso debe ser clara, precisa y no dejar lugar a duda alguna, dado que lo obrado por la Convención Constituyente goza de la presunción de legitimidad que le otorga la elección popular de sus integrantes" (13).

Recordemos en este orden de ideas que el 19 de agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad del art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma de 1994, en una decisión que despertó serias objeciones (14).

6. LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Veremos a continuación las reformas que siguen vigentes de la Constitución de 1853. Por tener mero "valor arqueológico", no analizaremos en esta ocasión las de 1949 y 1972.

a) La llamada reforma de 1860

Al compulsar la relevancia de los cambios constitucionales operados en 1860 sobre la estructura estatal, Spota no vacila en afirmar que en 1860 nos hallamos en presencia de poder constituyente originario y no derivado, opinión que comparte Germán Bidart Campos.

En efecto, al dato histórico-sociológico de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación y al político de la Batalla de Cepeda, hay que sumar el tenor de los cambios introducidos, sobre todo en orden a un fortalecimiento de los poderes provinciales sobre el federal. Concretamente, la Provincia de Buenos Aires logró incrementar dichas facultades en materia de reforma constitucional, legislación sobre prensa, procesal, ciudad capital, etc.

(13) V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada*, Buenos Aires, 2001, p. 237.

(14) V. HERNÁNDEZ, ANTONIO MARÍA, *El 'caso Fayt' y sus implicancias constitucionales*, ob.cit.

b) La reforma de 1866

Los cambios introducidos se refirieron a la extensión "sine die" de los derechos de exportación contenidos en los arts. 4º y ex 67 inc. 1.

c) La reforma de 1898

Se aprobó la reforma del ex art. 37 en cuanto a la base poblacional de representación de los diputados nacionales y el cambio del ex art. 87 sobre cantidad de ministros del poder ejecutivo.

d) La reforma de 1957

Producida en 1956 la vuelta a la Constitución de 1853 con sus reformas (excluyendo la que se había operado en 1949), se agregaron dos normas: el art. 14 bis, que incorpora contenidos mínimos del constitucionalismo social (ver *supra*) (15) y una mención, en similar tónica, en el ex art. 67 inc. 11 (hoy 75 inc. 12) al código del trabajo y seguridad social.

e) La reforma de 1994

Bajo el telón de fondo del acuerdo cupular entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem llamado "Pacto de Olivos", se decide por ley 24.309 convocar a una reforma constitucional. Una de sus peculiaridades es que la propuesta de temario contenía una cláusula cerrojo, el denominado "Núcleo de Coincidencias Básicas", que debía ser aprobado o desechado en bloque (art. 2º). Entre sus ítems figuró la tan controvertida reelección presidencial que quedó para muchos en el imaginario social como el principal motivo generador de los cambios propugnados. Luego estaban otros asuntos que estaban habilitados para su tratamiento por parte de la Asamblea Constituyente, como la jerarquía de los tratados de derechos humanos, la protección ambiental o la acción de amparo. La parte dogmática en sí estaba "petrificada" por el art. 7º del cuerpo legal citado.

La reforma operada fue vasta en lo cuantitativo y en lo cualitativo, con fórmulas de textura abierta que requirieron desarrollo legislativo, que en algunos casos se encuentra aún pendiente.

f) Quid de una nueva reforma futura

En Argentina, luego de 1994, parece que "todo está escrito", sin que exista mucho motivo concreto para ensayar nuevas experiencias institucionales. En efecto, como vimos, la Constitución con sus agregados de 1994 aumentó exponencialmente la "explicitud constitucional", en detrimento de los "silencios

del constituyente", que cada vez fueron menos. En materia de derechos fundamentales, por ejemplo, casi no hay facultad subjetiva imaginable sin consagrar, fruto del ingreso de los mencionados tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, se advierte agudamente una falta de cumplimiento leal y sincero tanto por detentadores como por destinatarios del mandato integral de 1853-1994. Sobre todo, se advierte una carencia en el despliegue reglamentario que debe hacer el Congreso de aquellos preceptos incorporados en 1994.

Un fenómeno generalizado en América Latina es la falta de controles institucionales del poder, o su virtualidad muy mermada. Se prefiere asegurar la "eficacia decisoria", a que la decisión que se arribe sea el producto del debate reflexivo y racional. La deliberación pasa a un segundo plano, extraviando la esencia del constitucionalismo que, en la visión del maestro Karl Loewenstein (16), se caracterizaba por la distribución del poder con existencia de controles adecuados.

Ello hace que, al menos en lo que concierne al caso argentino, la discusión no pase tanto por convocar una nueva Asamblea Constituyente, con todos los riesgos que ello traería aparejado (desde la cooptación hasta la degradación técnica de la redacción), como por reactivar los mecanismos legales e incluso judiciales para tornar operativas las directivas constitucionales.

(15) V. CARNOTA, WALTER F., "El artículo 14 bis a la luz de la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Homenaje y Balance", en LA LEY, Suplemento de Derecho Constitucional, 28/12/07, p. 32.

(16) V. LOEWENSTEIN, KARL, *Teoría de la Constitución*, Barcelona, 1979, p. 51.

CAPITULO II

EMERGENCIA ECONÓMICA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Deslindes conceptuales. — 3. La Constitución como instrumento permanente. — 4. El caso "Massa". — 5. Conclusión: el círculo vicioso de la emergencia.

1. INTRODUCCIÓN

Si el siglo XX ha sido la centuria del predominio del poder ejecutivo sobre los demás órganos públicos, ese acrecentamiento de funciones fue de la mano de la asunción de mayores cometidos por parte del Estado y de las recurrentes "emergencias", sobre todo en el campo socio-económico.

Alguna vez bien se dijo que así como las primeras emergencias convalidadas por nuestra Corte Suprema fueron hijas de la "emergencia de la sociedad" (así, en las décadas de 1920, 1930 y siguientes), las que acontecieron en la década de 1990 fueron producto de una "emergencia del Estado", en constante bancarrota y con sus cuentas sin cerrar.

Efectivamente, ya en "*Ercolano*" (1), el Alto Tribunal declaró en 1922 que la ley 11.157, que prohibía cobrar, durante dos años contados desde su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que se pagaba al 1 de enero de 1920, era constitucional. En 1934, la Corte sostuvo en "*Avico*" (2) la constitucionalidad de la ley 11.741, que reducía el interés y prorrogaba el plazo para el pago del capital en un préstamo hipotecario. Diez años más tarde, en "*Inchauspe*" (3), el Tribunal ratificó la relatividad del derecho de propiedad.

Y en 1990, en "*Peralta*" (4), la emergencia llega a su máxima expresión, al estimarse que el dec. 36/90 de conversión de plazos fijos en títulos de la deuda pública era constitucional.

(1) Fallos: 136: 161.

(2) Fallos: 172: 21.

(3) Fallos: 199: 483.

(4) Fallos: 313: 1513.

La emergencia del Estado nos ha corroído en los últimos años, a tenor de lo sustentado en "Bustos" (5) y sus secuelas jurisprudenciales, que legitiman la pesificación asimétrica. ¿Es la emergencia económica completamente antitética a la Constitución? ¿Cómo contenerla?

2. DESLINDES CONCEPTUALES

Convencionalmente, se distingue entre la "situación de emergencia", que es un acontecimiento anómalo que se produce en el terreno de los hechos, y el "remedio de emergencia", que es el instrumento jurídico destinado a conjurar la primera (6).

Nuestra Constitución histórica de 1853-1860, como producto de graves situaciones de emergencia que le dieron origen, previó estos instrumentos, al consagrar institutos tales como la intervención federal (art. 6º) y el estado de sitio (art. 23). La legislación tanto de "iure" cuanto de "facto" (en donde todo es emergencial) fueron creando mecanismos de diversa laya, entre los que han sobresalido en las últimas décadas los relativos a la regulación económica.

Por su parte, la reforma constitucional de 1994 introdujo la "delegación legislativa" (art. 76) y los "decretos de necesidad y urgencia" (art. 99 inc. 3), con formulaciones de textura muy abierta y hasta contradictorias. En efecto, ambas disposiciones comienzan con aparentes prohibiciones, para concluir con permisiones latas.

Sabido es que la Constitución no sólo es un documento político, sino que en sí contiene una "constitución económica" en donde se halla contenido el ordenamiento socio-económico del Estado. Así, las libertades económicas, las potestades impositivas del Estado y la ejecución presupuestaria, entre otros importantes tópicos, integran esta noción.

Pero, en paralelo a una "constitución económica" de la normalidad, de la paz y del sosiego, se ha desarrollado otro cuerpo —¿una anti-constitución? (7)— signada por los recurrentes episodios críticos, que siempre han terminado con mayores intervenciones del Estado, en particular del órgano ejecutivo, que constantemente ha reclamado mayores poderes para hacerles frente.

3. LA CONSTITUCIÓN COMO INSTRUMENTO PERMANENTE

Así como puede sostenerse que la Constitución no depone su vigencia sociológica porque el Estado se halle en conflictividad o en guerra (interna o

externa), lo mismo cabe predicar respecto de las recurrentes crisis en materia socio-económica.

En tal sentido, se han elaborado diversos "tests" que procuran poner algún coto o límite a la permanente invocación de la emergencia como condicionante del ejercicio de los derechos individuales.

Se ha esbozado, en la referida causa "Avico" y siguiendo las aguas de la jurisprudencia norteamericana ("*Home Building and Loan Association v. Blaisdell*") que la emergencia, para ser válida, debe reunir los siguientes recaudos o extremos:

- a) existencia de una situación de emergencia;
- b) la sanción de una ley que proteja los intereses generales de los ciudadanos;
- c) que exista proporción de medio a fin (razonabilidad); y
- d) temporalidad.

Cabe considerar que los principios de legalidad y de razonabilidad deben estar presentes en toda reglamentación de derechos subjetivos, sea ésta permanente o transitoria.

Por el contrario, el hecho de que la legislación de emergencia se encamine hacia el bienestar general, y que haya un límite de tiempo, son requisitos específicos que harán constitucionalmente viable (o no) a la excepcionalidad esgrimida. Recordemos que ya en Roma la famosa institución de la "dictadura" tenía una valla temporal de seis meses.

En definitiva, estas cortapisas apuntan a incluir a la emergencia en el diagrama constitucional, y no que subsista como un cuerpo extraño a la Ley Mayor, con sus propias reglas y principios.

4. EL CASO "MASSA" (8)

Antes de concluir el año 2006, la Corte Suprema se despidió de la actividad judicial con un fallo que promete controversias pero cuyo único objetivo ha sido poner punto final a los litigios relativos a la pesificación. Luego de cinco años, las circunstancias cambiantes del sistema económico-financiero permitieron una decisión más teñida con la equidad (1,40 más CER más tasa de interés de 4 % no irrogaría daño al actor), que con el derecho estricto (inconsistencia del "bloque de emergencia" con el art. 17 constitucional). Los hechos parecen haber ganado a las normas (9).

(5) Fallos: 327: 4495.

(6) V. CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 157.

(7) A esto parecería conducir la "emergencia permanente".

(8) M. 2771. XLI. — "Massa, Juan Agustín c. Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986" — CSJN — 27/12/2006 (elDial - AA3ACA).

(9) CARNOTA, WALTER, "El fin de una era: cómo resuelve la pesificación la nueva corte" (nota al fallo "Massa"), elDial - DCA9A.

Quien quiera encontrar rigor técnico en este pronunciamiento, no lo hallará, ni siquiera en los esfuerzos de los jueces Fayt y Argibay por aclarar más las cosas. Empero, del voto mayoritario podemos inducir ciertas tendencias que no sólo interesan en lo concerniente a la pesificación, sino a cómo administra justicia esta Corte.

El Tribunal es plenamente consciente de su más elevada función institucional, es un cuerpo que privilegia el consenso entre sus integrantes, que quiere el debate interno para amalgamar posiciones, y que ve más allá de la causa concreta, lo que podríamos denominar "consecuencialismo". Desde "Itzcovich" (Fallos: 328:566) y "Verbitsky" (Fallos: 328:1146) en 2005, el Tribunal transita esta ruta, afirmada este año en "Mendoza" (Fallos: 329:2316) y en "Badaro I" (Fallos: 329:3089), más de Corte Constitucional que de último peldaño de la justicia federal. Establece grandes lineamientos, no la solución puntual para cada caso. Estamos en presencia de una decisión de la nueva Corte, ya que salvo el caso de Fayt, los otros cuatro jueces son los más recientes. No nos olvidemos: ésta es una Corte más constitucional que suprema.

Y así se dicta un pronunciamiento pacificador, que quiere dar vuelta la página a una historia que hoy representa 60.000 acciones. Como en "Badaro I", seguramente este decisorio dejará muchas preguntas sin contestar, jueces de las instancias inferiores asombrados intentando delimitar sus alcances y litigantes disconformes.

Si bien, contrariamente a lo que se afirma con rotundez, no creemos que la propiedad y el derecho a contratar hayan salido del todo bien parados en el trance, reconocemos que la evitación del daño ha guiado la sentencia del Tribunal. Del daño individual y del colectivo. Ese también es un valor constitucional a computar.

La pesificación de comienzos de siglo fue la respuesta (o mejor dicho, la reacción) a la convertibilidad de los noventa. El Tribunal, más por el transcurso del tiempo que por la persuasión argumental ("cronoterapia"), procura poner fin a tanto desquicio (10).

5. CONCLUSIÓN: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA EMERGENCIA

En su ampliación de voto en el caso "Massa", el juez Ricardo Lorenzetti señala agudamente que "el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario volver a la normalidad".

(10) V. CARNOTA, WALTER F., "La pesificación hoy ('cronoterapia' y realismo)", en Suplemento Especial LA LEY, 29/12/2006, p. 13.

PARTE TERCERA

PRINCIPIOS, DERECHOS Y CLÁUSULAS CONSTITUCIONALES

CAPITULO I

LA EFECTIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS DERECHOS

SUMARIO: 1. Preliminar. — 2. Dominio de la ley o de los derechos fundamentales. — 3. Reglamentaciones e interpretaciones fieles. — 4. La declaración de derechos es en principio operativa. — 5. La fuerza normativa de la Constitución.

I. PRELIMINAR

¿Qué significa señalar que los derechos son directamente operativos? En principio, implica sostener que ineludiblemente no requieren de una reglamentación.

Esta idea de la operatividad se hallaba ínsita en el constitucionalismo clásico, que de todas maneras no la formulaba conceptualmente así. En efecto, las constituciones de los s. XVIII y XIX se preocuparon antes que nada por enunciar las distintas facultades subjetivas (las llamadas "libertades públicas"), sin decir explícitamente que no necesitaban de adicional despliegue legislativo.

Es más, algunos textos, tal como acontece con nuestro art. 14, parecían sugerir precisamente la noción contraria, es decir, el carácter imprescindible de la intervención posterior del órgano Congreso.

2. DOMINIO DE LA LEY O DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

De todos modos, es dable destacar que el primigenio constitucionalismo acentuaba el rol del legislador (ver, para nuestra Ley Mayor, los arts. 14 cit., 16, 17, 18, 19 y concordantes). La que expropia, la que fija penas, la que regula, en principio, es *la ley*, emparentándose todo ello con la noción rousseauniana de que "la ley es expresión de la voluntad general".

Empero, el constitucionalismo del s. XX, sobre todo el de sus últimas décadas, es un "constitucionalismo de derechos" o "basado en derechos". Los

derechos humanos o fundamentales asumen tal importancia, que es menester que los poderes públicos los aseguren, afiancen o garanticen, más allá de las respectivas fórmulas verbales o lexicales.

Nuestro art. 14 reconoce derechos "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio", en una nueva reafirmación del principio de legalidad.

A su vez, el art. 28 veda que las leyes reglamentarias alteren los derechos, lo que se conoce entre nosotros como principio de razonabilidad.

Por su parte, el art. 75 inc. 23 insiste en garantizar "el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos".

3. REGLAMENTACIONES E INTERPRETACIONES FIELES

En definitiva, últimamente lo que el constitucionalismo busca es achicar la brecha entre validez y vigencia. En otros términos, se procura que la declaración de derechos no sea meramente declamatoria, expresiva de deseos del autor de la norma, sino norma positiva, en el sentido de que sea real y concreta en el plano de las conductas.

Para ello, las reglamentaciones que dicte el Congreso a través de normas generales como son las leyes, o las interpretaciones aplicativas que hacen los magistrados judiciales, como son las sentencias, deben ser "fieles", es decir, consistentes y congruentes con las mandas constitucionales.

Todos los mecanismos de control y de garantías que instituye la Constitución, apuntan a evitar estas tergiversaciones, muy comunes en democracias poco consolidadas, orientadas a lo que Loewenstein denominaba "constituciones nominales".

Se requiere de una sólida "cultura constitucional" para evitar estos abusos del poder, y que sea la misma sociedad la que los reprueba, ya sea electoralmente, o activando los instrumentos de defensa de la Constitución previstos por el propio texto.

4. LA DECLARACIÓN DE DERECHOS ES EN PRINCIPIO OPERATIVA

Decimos pues que el "bill" de derechos contiene una *presunción* de operatividad. No se necesita más que la consagración del derecho para que el mismo funcione, salvo que el constituyente haya redactado la norma en clave de "programa" o de "futuro". En ese caso, el derecho es "programático" y no directamente operativo.

Igualmente, aún en el supuesto de una norma programática (como podría ser "la participación en las ganancias de las empresas", del art. 14 bis), eso

no significa dejar librado el dictado de la norma reglamentaria a la total discreción del Congreso. De no sancionarse en un lapso razonable esa normativa, se verifica la "inconstitucionalidad por omisión", dado que el Congreso debió hacer algo que la Ley Suprema le ordenaba realizar (1).

5. LA FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN

Para entender cabalmente toda esta problemática, debe tenerse muy presente que la Constitución no es una suma o compendio de consejos, como tampoco es un catálogo de ilusiones o de expresiones de deseos.

La Constitución es norma vinculante (*binding law*), que ata a gobernantes y a gobernados más que un código o una ley ordinaria.

Nuestra concepción del derecho, derivada del sistema continental romanista, es muchas veces muy afecta a la ley y poco a la Constitución. Las inconsistencias entre la ley 16.986 y el art. 43 constitucional es un claro ejemplo de ello.

Al contrario, si se comprende y asume que la Constitución es "norma de normas", no hay margen o tolerancia para desobediencias o desnaturalizaciones. Ello implica captar en todas sus ramificaciones a la pirámide normativa.

Hay autores alemanes y españoles que han trabajado mucho el concepto de la "fuerza normativa de la Constitución". Este bagaje conceptual apunta a que la directiva constitucional se realice a través de dispositivos y mecanismos jurisdiccionales aptos. Incluso también se orienta a que cuando haya omisiones inconstitucionales, las mismas sean subsanadas. Y cuando el Estado a nivel interno es incapaz de cumplir los derechos fundamentales a los que se ha comprometido internacionalmente, se encuentre incurso en responsabilidad internacional.

(1) V. CARBONELL, MIGUEL (Coordinador), *En busca de las normas ausentes (Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión)*, México, 2003.

CAPITULO II

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Los derechos de primera generación. — 3. Los derechos de segunda generación. — 4. Los derechos de tercera generación. — 5. Los derechos sociales sustentables como derechos de cuarta generación. — 6. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El movimiento del *constitucionalismo clásico o liberal* surgió como una respuesta de la burguesía, respecto del absolutismo monárquico imperante hasta el s. XVIII. Fue al final de esta centuria, de la mano de la Revolución norteamericana (1776) y de la Revolución francesa (1789), que los primeros textos constitucionales se ocuparon y preocuparon por incluir a los derechos más importantes y trascendentes de la persona humana.

A los fines de este capítulo, vamos a tratar como sinónimos la expresión "*derechos fundamentales*", de aquí en adelante dentro del Derecho Constitucional, con otras que son próximas: derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos naturales, derechos humanos. Cada una de ellas tuvo un determinado contexto histórico, pero todas conllevan la noción de facultades o potestades del ser humano frente al poder, que se hallan expresa o implícitamente en la norma constitucional.

Dentro de este orden de ideas, el art. 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresa que: "*Todo Estado en el cual no se consagre la división de poderes ni se reconozcan los derechos individuales carece de Constitución*".

La declaración o "bill" de derechos se revela así como un elemento esencial del Estado constitucional. Al Estado constitucional, no le es neutro, ni indiferente, contar con una declaración de derechos. Por el contrario, el constitucionalismo clásico o liberal va a estar signado por la presencia de esa enunciación.

2. LOS DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN

Históricamente, aparecen al comienzo del constitucionalismo los derechos civiles y políticos, denominados por la doctrina "derechos de primera

JB

generación", por el momento inicial en que irrumpen. La libertad y sus múltiples formas (libertad de prensa, libertad religiosa, autonomía personal), la igualdad, la seguridad personal, el sufragio tanto activo como pasivo, son todos derechos básicos del ser humano que son susceptibles de ser catalogados dentro de este primer rubro.

Todos estos derechos se van a caracterizar por irrogar al Estado una obligación de tipo *negativo*, un deber de abstención. Así, el Estado no debe perseguir a los cultos religiosos, no debe coartar la libertad de expresión de ideas, no debe turbar la seguridad individual, etc.

Al promediar el s.XIX, emerge la llamada "Revolución Industrial" que, fruto de la evolución técnica y del maquinismo trastoca y altera las relaciones económicas y sociales. La llamada "cuestión obrera" o "cuestión social" va a tener distintas respuestas en sede doctrinal, desde las diversas clases de socialismo hasta la Doctrina Social de la Iglesia. Todas estas corrientes filosóficas van a confluir en la escuela del denominado "constitucionalismo social".

3. LOS DERECHOS DE "SEGUNDA GENERACIÓN"

En las primeras décadas del s.XX, va a surgir con fuerza el movimiento del "constitucionalismo social" ya aludido. Sus primeras manifestaciones normativas van a estar dadas por la Constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919.

Las premisas básicas sobre las que va a descansar esta Escuela es que al lado de los derechos básicos ya estudiados, se van a reconocer derechos en el plano económico-social: derechos del trabajador, de los gremios, de la previsión social, de la asistencia sanitaria, de la cultura y la educación, etc. No se ve al individuo aislado o sólo frente al poder público, sino que se lo visualiza integrando grupos: la familia, el sindicato, el partido político, la comunidad empresarial, etc.

Para su consecución, el Estado va a estar investido ya no de "obligaciones negativas" como en la etapa o fase anterior, sino positivas. Concretamente, el poder público va a tener que brindar determinadas prestaciones (de ahí el nombre de "derechos prestacionales" o del "bienestar"), es decir, tendrá que cumplimentar obligaciones de dar.

El constitucionalismo social se va a propagar sobre todo luego de la segunda posguerra: la Constitución italiana de 1947, la alemana de 1949, la portuguesa de 1976, la española de 1978, la peruana de 1979, la colombiana de 1991, etc.

La idea central del "constitucionalismo social" está dada por el art. 3º de la citada Constitución italiana de 1947, cuando habla de la "remoción de obstáculos" que impida fácticamente la igualdad de las personas. El Estado, dentro de este esquema, va a asumir un rol pro-activo y presencial en la gestión del

bienestar general. No siempre se ha considerado que los derechos económico-sociales son verdaderos "derechos", ya que muchas veces se ha evidenciado empíricamente su desconocimiento o violación.

4. LOS DERECHOS DE "TERCERA GENERACIÓN"

Hacia la década de 1960 y de 1970, hacen su aparición los derechos más nuevos e incipientes, frente a cambiantes realidades y necesidades humanas y sociales. Se trata de los llamados "derechos de tercera generación": la protección al ambiente, al usuario y al consumidor, el derecho a la paz, al desarrollo sustentable, etc. Son derechos que primeramente ven la luz en el seno de la cooperación internacional, y luego se filtran a los ordenamientos constitucionales, como sucedió entre nosotros a nivel federal con la reforma del año 1994 (arts. 41, 42 y 43).

En este contexto, el Estado tendrá que desplegar políticas para favorecer su desarrollo (obligaciones de hacer).

5. LOS DERECHOS SOCIALES SUSTENTABLES COMO DE CUARTA GENERACIÓN (1)

Sin lugar a dudas los tratados internacionales con jerarquía constitucional han efectuado un muy importante aporte, regulando, ampliando y obligando a los Estados partes a llevar medidas positivas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, en beneficio del bienestar general de todos los países de América.

En un mundo globalizado si se suscitan crisis económicas o políticas en un país, las consecuencias serán sufridas en forma inmediata en los estados vecinos y luego en forma mediata al resto del continente (ej. el caso "Tequila" en México; "Caipirinha" en Brasil, "efecto tango" argentino), es por ello, que el desarrollo y progreso de sus miembros se basa en la ayuda y cooperación mutua en sus diferentes aspectos económicos, sociales y educativos.

Las nuevas perspectivas que hoy existen en el derecho previsional podemos ubicarlo para su mejor funcionamiento en los derechos de cuarta generación, y no como derechos de segunda generación, pues de este modo ayudamos a un mejoramiento procesal con la posibilidad de iniciarse acciones colectivas o *class actions*, agrupando y agilizando los tiempos en los juicios en materia de seguridad social.

Prueba de ello, el art. 75 inc. 23 de la CN, estipula que el congreso federal deberá legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la

(1) Ver asimismo MARANELLO, PATRICIO A., panel sobre régimen de capitalización individual, en el marco del IV Congreso Argentino de Previsión Social, realizado en septiembre de 2006 en la ciudad de Catamarca.

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos.

En esta última regulación es cuando internacionalizamos los derechos sociales (art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), así como otros derechos que apliquen principios del derecho internacional y órganos con facultades jurisdiccionales internacionales.

También debe evocarse el prisma de la sustentabilidad, que de un análisis extensivo del art. 41 surge al hablar de que las actividades productivas que deben satisfacer las necesidades presentes no deben comprometer a las futuras. Los aportes que se hagan tienen que servir para beneficiar a las generaciones presentes y futuras.

Esta etapa se caracteriza por la "cooperación internacional" del art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece la misma para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la OEA.

6. CONCLUSIONES

La apuntada clasificación en clave histórica se orienta hacia un intento pedagógico por ordenar la aparición sucesiva de los derechos fundamentales. Bajo ningún punto de vista se encamina a privilegiar unos sobre otros, ni anteponerlos o antagonizarlos. Todos los derechos son importantes y se implican entre sí, dentro del esquema del Estado Constitucional de Derecho.

CAPITULO III

DERECHO AMBIENTAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Regulación normativa. — a) Antecedentes. Conferencias y Tratados Internacionales. b) Antecedentes provinciales. c) Otros antecedentes constitucionales. d) Las primeras leyes ambientales en el derecho comparado. e) Leyes nacionales y/o provinciales. — 3. Jurisprudencia nacional y/o provincial. a) Antes de la reforma constitucional. b) Después de la reforma constitucional. — 4. Protección administrativa y judicial del entorno. — 5. Desarrollo sustentable. — 6. La audiencia pública como medio probatorio en lo derechos de incidencia colectiva. a) A modo de introducción. b) La garantía de ser oído y la audiencia pública. c) El marco constitucional y legal. d) La esfera reglamentaria. e) Proyección jurisprudencial. f) Su extensión al ámbito jurisdiccional. g) Beneficios que encuentra la doctrina en las audiencias públicas. h) Recapitulaciones. — 7. Los tribunales judiciales ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. a) Introducción. b) Situación en el derecho comparado. b.1) Guatemala. b.2) Honduras. b.3) Costa Rica. b.4) Panamá. b.5) Brasil. b.6) España. c) Opinión de la doctrina especializada. d) Proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. d.1) Principio de gratuidad. d.2) Impulso de oficio. e) Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Podemos considerar que los problemas ambientales aparecieron en el neolítico, con el comienzo de la tala de bosques y los primeros cultivos. La preocupación por la degradación del ambiente se manifestó de diferentes maneras a lo largo de la historia de la humanidad, pero en la actualidad, las modificaciones de los ecosistemas naturales y la contaminación son causa de honda investigación por parte de científicos, técnicos y juristas, ya que están afectando incluso el equilibrio ecológico del planeta.

El uso ilimitado que ha realizado el hombre de los bienes y servicios ambientales ha dado lugar a profundas modificaciones dentro de su entorno, las cuales repercuten en forma última, sobre su calidad de vida. El reconocimiento de estas modificaciones dio pie a la creación de medidas jurídicas encaminadas a la protección y uso racional del ambiente. Las primeras legislaciones modernas que pudiesen ser definidas como ambientales, surgen del reconocimiento de la contaminación ambiental como un problema de salud